

Neue Tendenzen des Verwaltungsrechts im Zeitalter der Privatisierung

Keynote Address

(Delivered on November 19, 2011)

Hartmut Bauer*

Contents

- I. Einleitende Problemskizze
- II. Privatisierungsbegriff, Privatisierungsfelder und Privatisierungsmotive
- III. Privatisierungstypologie, Mischformen, Differenzierungen und Übergänge
- IV. Stellschrauben zur normativen Steuerung von Privatisierungsprozessen
- V. Ansatzpunkte zur dogmatisch-systematischen Erfassung rechtlich gestalteter Privatisierungswirklichkeit
- VI. Zukunftstrend (Re-)Etatisierung und (Re-)Kommunalisierung?
- VII. Ausblick

* Lehrstuhl für Europäisches und Deutsches Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Sozialrecht und Öffentliches Wirtschaftsrecht, Juristische Fakultät, Universität Potsdam. Meinen Assistenten *Dr. Kai-Holmger Kretschmer* und *Lydia Hajasch* danke ich für ihre Unterstützung bei der Vorbereitung dieses Beitrags.
〔責任校對：陳嫻恬〕。

I. Einleitende Problemskizze

Privatisierungen sind der Sache nach in Deutschland zwar alles andere als neu¹. Sie haben seit geraumer Zeit aber einen enormen Bedeutungszuwachs erfahren. Äußerlich ablesbar ist der Bedeutungszuwachs nicht zuletzt an der besonderen Aufmerksamkeit, mit der die Rechtswissenschaft den Privatisierungstrend begleitet: Mehrere Habilitationsschriften², zahlreiche Dissertationen und unzählige Aufsätze haben sich mit dem Thema befasst. Hinzu kommt eine längst nicht mehr überschaubare Vielzahl von Fachtagungen, darunter in der jüngeren Vergangenheit nicht weniger als zwei Staatsrechtslehrertagungen³ und unlängst auch ein Deutscher Juristentag⁴.

Zeitlich überschneidet sich der Beginn der aktuellen Privati-

-
- 1 Vgl. zur Geschichte der Privatisierung, die älter ist als der Begriff, *Jörn Axel Kämmerer*, Privatisierung, 2001, S. 61 (61 ff.).
 - 2 Insbesondere *Martin Burgi*, Funktionale Privatisierung und Verwaltungshilfe, 1999; *Kämmerer* (Fn. 1); *Wolfgang Weiß*, Privatisierung und Staatsaufgaben, 2002; *Christof Gramm*, Privatisierung und notwendige Staatsaufgaben, 2001; *Barbara Remmert*, Private Dienstleistungen in staatlichen Verwaltungsverfahren, 2003.
 - 3 Siehe zum Beratungsgegenstand „Privatisierung von Verwaltungsaufgaben“ der Jahrestagung 1994 die Berichte von *Johannes Hengstschläger*, *Lerke Osterloh* und *Hartmut Bauer* sowie den Länderbericht von *Tobias Jaag*, VVDStRL 54 (1995), S. 165 ff., 204 ff., 243 ff., 287 ff.; zum Beratungsgegenstand „Beteiligung Privater an der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und staatliche Verantwortung“ der Jahrestagung 2002 die Berichte von *Markus Heintzen* und *Andreas Voßkuhle*, VVDStRL 62 (2003), S. 220 ff., 266 ff. Mit in diesen Kontext gehört auch der Beratungsgegenstand „Die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben durch Private“ der freilich schon weiter zurückliegenden Jahrestagung 1970 mit Berichten von *Fritz Ossenbühl* und *Hans-Ullrich Gallwas*, VVDStRL 29 (1971), S. 137 ff., 211 ff.
 - 4 Dazu *Martin Burgi*, Privatisierung öffentlicher Aufgaben – Gestaltungsmöglichkeiten, Grenzen, Regelungsbedarf, Gutachten D für den 67. Deutschen Juristentag, 2008; der dazugehörige Sitzungsbericht mit Referaten von *Joachim Wieland*, *Thomas von Danwitz* und *Thomas de Maizière* findet sich in Teil M der Verhandlungen des 67. Deutschen Juristentages in Erfurt 2008.

sierungswelle in etwa mit der Wiedervereinigung. Nach schon in den 1980er Jahren zu beobachtenden Vorstößen haben Privatisierungsbestrebungen nämlich erst in den 1990er Jahren „volle Fahrt“⁵ aufgenommen. Die Koinzidenz ist kein Zufall. Schon allein von der umfangreichen Privatisierung der früheren Staatsbetriebe der DDR durch die Treuhandanstalt⁶ und der Einbindung Privater in die Erneuerung maroder Infrastrukturen in Ostdeutschland gingen wichtige Impulse für die Forderung nach einer „Privatisierung auch im Westen“⁷ aus. Vor allem aber setzten die als Folge der Wiedervereinigung sprunghaft angestiegenen Defizite der öffentlichen Haushalte⁸ ein klares finanzpolitisches Signal. Das „Diktat der leeren Kassen“ legte zur Rückführung des Schuldenstandes die Veräußerung von Vermögenswerten der öffentlichen Hand nahe und zur Staatsentlastung den Rückzug der öffentlichen Hand aus bislang von ihr wahrgenommenen Aufgaben. Verstärkt wurde der Privatisierungstrend durch ordnungspolitische Überlegungen und ganz allgemein durch eine politische

5 So auch die Einschätzung von *Friedrich Schoch*, Die Rolle der Rechtsdogmatik bei der Privatisierung staatlicher Aufgaben, in: Stürner (Hrsg.), Die Bedeutung der Rechtsdogmatik für die Rechtsentwicklung, 2010, S. 91 (91).

6 Bei der „Transformation der auf Volkseigentum und staatlicher Lenkung beruhenden Planwirtschaft in eine auf Privateigentum und Individualfreiheit beruhende Marktwirtschaft“ (BVerfGE 95, 267 [308]) spielte die Treuhandanstalt eine herausragende Rolle. Ihr kam nämlich die Herkulesaufgabe zu, die früheren volkseigenen Betriebe wettbewerblich zu strukturieren und zu privatisieren. Mit anfangs 8000 Unternehmen, 40000 Betriebsstätten und sechs Millionen Beschäftigten galt sie als die größte Holding der Welt (*Fritz Ossenbühl*, Eigentumsfragen, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts (HStR), Bd. IX, 1987, § 212 Rn. 8).

7 Programmatisch seinerzeit etwa Kronberger Kreis, Privatisierung auch im Westen, 1993.

8 Schon bald nach der Wiedervereinigung rechnete man mit einer Verdoppelung der Staatsverschuldung auf über zwei Billionen DM; siehe zu den damaligen finanzpolitischen Szenarien *Hartmut Bauer*, Die finanzverfassungsrechtliche Integration der neuen Länder, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts (HStR), Bd. IX, 1987, § 206 Rn. 1 ff., 41 ff.

Grundströmung, in der Privatisierungsoptionen eine wichtige Rolle bei der Zukunftssicherung des Standortes Deutschland spielten.⁹ Frühe Highlights im konjunkturellen Höhenflug der Privatisierung waren die Reformen und Umstrukturierungen bei der Deutschen Bundespost¹⁰ und der Deutschen Bundesbahn¹¹, daneben Privatisierungsmaßnahmen in Segmenten der kommunalen Daseinsvorsorge.

Zumindest vordergründig scheint der Trend ungebrochen. Ein anschaulicher Beleg aus jüngerer Zeit ist die gesetzliche Verbesserung der Rahmenbedingungen für Public Private Partnerships¹². Damit verbinden manche einen auf allen Ebenen (Bund, Länder und Kommunen) und über Parteigrenzen hinweg bestehenden, auch auf der europäischen Ebene erkennbaren¹³ „Grundkonsens, Public Private Partnerships zu fördern“¹⁴. In dieselbe Richtung weist aktuell eine geplante Novellierung des Verwaltungsverfahrensgesetzes, mit der Kooperationsverträge, die solche Öffentlich Privaten Partnerschaften begründen und regeln, auf eine sichere gesetzliche Grundlage gestellt

9 Näheres zur politischen Ambiance Anfang der 1990er Jahre bei *Friedrich Schoch*, Privatisierung von Verwaltungsaufgaben, DVBl. 1994, S. 962 (965 ff.); *Bauer* (Fn. 3), S. 245 ff.

10 Dazu *Johannes Masing*, Post und Telekommunikation, in: Handbuch des Staatsrechts (HStR), Bd. IV, 3. Aufl., 2006, § 90 Rn. 16.

11 Dazu *Robert Uerpmann-Wittzack*, Verkehr, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts (HStR), Bd. IV, 3. Aufl., 2006, § 89 Rn. 5 ff., 41 f.

12 Gesetz zur Beschleunigung der Umsetzung von Öffentlich Privaten Partnerschaften und zur Verbesserung gesetzlicher Rahmenbedingungen für Öffentlich Private Partnerschaften vom 1. 9. 2005 (BGBl I S. 2676).

13 Vgl. *Hartmut Bauer*, Verwaltungsverträge, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. II, 2. Aufl., 2012, im Erscheinen, § 36 Rn. 42 m.w.N.

14 *Michael Uechtritz/Olaf Otting*, Das „ÖPP-Beschleunigungsgesetz“: Neuer Name, neuer Schwung für „öffentlich-private Partnerschaften“?, NVwZ 2005, S. 1105 (1105 [Zitat], 1111).

werden sollen¹⁵. Die gesetzlich intendierte Förderung von Public Private Partnerships bestätigt den seit über zwanzig Jahren anhaltenden Privatisierungstrend, der es rechtfertigt, von einem „Zeitalter der Privatisierung“ zu sprechen.

Indes könnte das Zeitalter der Privatisierung heute bereits seinen Zenit überschritten haben und sich vielleicht sogar schon seinem Ende zuneigen. Inzwischen mehren sich nämlich jedenfalls in Deutschland die Anzeichen für einen Stimmungsumschwung und eine Trendwende¹⁶. So ist bei dem Großprojekt „Deutsche Bahn“ die Privatisierung ins Stocken geraten¹⁷, im Verwaltungskooperationsrecht ist die erwähnte privatisierungsinspirierte Novellierung des Verwaltungsverfahrensgesetzes vorerst zurückgestellt¹⁸, und auch im Übrigen ist hierzulande zunehmend von (Re-)Etatisierung und (Re-)Kommunalisierung die Rede¹⁹, mitunter gar von einem „Modetrend“²⁰ oder „Zukunftstrend“²¹

¹⁵ Dazu *Heribert Schmitz*, „Die Verträge sollen sicherer werden“ – Zur Novellierung der Vorschriften über den öffentlich-rechtlichen Vertrag, DVBl. 2005, S. 17 (17 ff.).

¹⁶ Vgl. dazu vorerst nur den Praxisbericht von *Roland Schäfer*, Rekommunalisierung: Modetrend oder neues Politikphänomen?, Öffentliche Finanzen, Sonderbeilage zur FAZ vom 19. 6. 2008, S. 3. Als Indikator für eine Trendwende mag auch das „Tagungsgeschäft“ gelten. Die Rekommunalisierung war im vergangenen Jahr Thema und Gegenstand einer Reihe von Fachtagungen mit überregionaler und deutschlandweiter Anziehungskraft – so im Oktober 2010 an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer, im April 2011 am Kommunalwissenschaftlichen Institut der Universität Potsdam, im Juni 2011 im Halleschen Forum für Verwaltungsrecht und im November 2011 am Institut für Kommunalrecht der Universität Osnabrück. Informationen zu all diesen und zahlreichen weiteren Veranstaltungen sind abrufbar im Internet.

¹⁷ Dazu *Sina Stamm*, Eisenbahnverfassung und Bahnprivatisierung, 2010, S. 234.

¹⁸ Die wiederholt in Angriff genommene Novellierung wurde bislang nicht umgesetzt; sie steht nach wie vor im Raum, ist aber wegen anderer, als vorrangig eingestuftes Vorhaben zur Fortentwicklung des Verwaltungsverfahrenrechts vorerst zurückgestellt (vgl. *Heribert Schmitz*, Kooperationsverträge, in: Bauer/Büchner/Brosius-Gersdorf [Hrsg.], Verwaltungskooperation, 2008, S. 51 [58 f.]).

¹⁹ Vgl. etwa *Peter Collin*, Privatisierung und Etatisierung als komplementäre

der Rekommunalisierung. „Insgesamt scheint gegenwärtig das Vertrauen in die Marktkräfte zu schwinden und nach einer Privatisierungseuphorie ist [...] ein Bedürfnis nach einer Renaissance klassischer Staatlichkeit zu spüren“²². Darauf wird zurückzukommen sein (VI).

Vorher sind privatisierungsspezifische Entwicklungstendenzen im deutschen Verwaltungsrecht vorzustellen. Wegen der Weite des Diskussionsfeldes und der Breite des Problemspektrums²³ kann es sich dabei nur um mehr oder weniger holzschnittartige Schlaglichter auf ausgewählte Eckpunkte der Privatisierung handeln, nämlich auf Privatisierungsbegriff, Privatisierungsfelder und Privatisierungsmotive (II), auf die Privatisierungstypologie und hybride Erscheinungsformen (III), auf Stellschrauben zur normativen Steuerung von Privatisierungsprozessen (IV) und auf Ansatzpunkte zur dogmatisch-systematischen Erfassung der Privatisierungswirklichkeit namentlich in einem Verwaltungskooperationsrecht (V).

Gestaltungsprozesse, JZ 2011, S. 274 (274 ff.); *Christoph Brüning*, (Re-) Kommunalisierung von Aufgaben aus privater Hand – Maßstäbe und Grenzen, VerwArch 100 (2009), S. 453 (453 ff.); *Manfred Röber*, Privatisierung adé?: Rekommunalisierung öffentlicher Dienstleistungen im Lichte des Public Managements, Verwaltung & Management 2009, S. 227 (227 ff.).

²⁰ *Schäfer* (Fn. 16), S. 3.

²¹ *Hartmut Bauer*, Verwaltungskooperation, in: Bauer/Büchner/Brosius-Gersdorf (Hrsg.), Verwaltungskooperation, 2008, S. 9 (22 f.).

²² *Rolf Stober*, Privatisierung öffentlicher Aufgaben, NJW 2008, S. 2301 (2301).

²³ Vgl. dazu neben der in Fn. 2 ff. angegebenen Literatur nur *Martin Burgi*, Privatisierung, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts (HStR), Bd. IV, 3. Aufl., 2006, § 75 m.w.N.

II. Privatisierungsbegriff, Privatisierungsfelder und Privatisierungsmotive

1. Privatisierungsbegriff und der Privatisierung zugängliche Aufgabenfelder

Ungeachtet gelegentlicher Verwendung in Gesetzestexten²⁴ verbinden sich mit dem Begriff „Privatisierung“ sehr variantenreiche Phänomene der Verlagerung von bislang durch die öffentliche Hand wahrgenommenen Angelegenheiten in den privaten Bereich und vorgelagerte Grauzonen.²⁵ Danach thematisiert das Stichwort „Privatisierung“ Umverteilungsprozesse zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor: Privatisierung meint Umverteilungsprozesse „hin zum Privaten“. Dieses Begriffsverständnis lässt offen, ob „sich die Verwaltung zur Erfüllung ihrer Aufgaben lediglich einer privatrechtlichen Organisationsform (z.B. GmbH, AG) bedient oder ob die Aufgabe von Beliehenen bzw. Verwaltungshelfern wahrgenommen wird oder ob gar eine Aufgabenverlagerung in den privaten Sektor („Entstaatlichung“) erfolgt“²⁶.

Von ähnlicher Offenheit ist der Begriff der Staatsaufgaben. Die

²⁴ So in § 7 Abs. 1 Bundeshaushaltsordnung („Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Diese Grundsätze verpflichten zur Prüfung, inwieweit staatliche Aufgaben oder öffentlichen Zwecken dienende wirtschaftliche Tätigkeiten durch Ausgliederung und Entstaatlichung oder Privatisierung erfüllt werden können.“) und entsprechenden Regelungen der Landeshaushaltsordnungen.

²⁵ Dazu und zum Folgenden jeweils m.w.N. *Bauer* (Fn. 3), S. 250 f.; *Rainer Schröder*, Verwaltungsrechtsdogmatik im Wandel, 2007, S. 148; *Schoch* (Fn. 5), S. 95; *Friedrich Schoch*, Rechtliche Steuerung der Privatisierung staatlicher Aufgaben, Jura 2008, S. 672 (672 ff.); eingehender zu den Definitionsproblemen etwa *Kämmerer* (Fn. 1), S. 16 ff. m.w.N.

²⁶ *Schoch* (Fn. 5), S. 95, mit näheren Ausführungen zur begrifflichen Offenheit.

bisweilen zu einseitig nach den „Grenzen der Privatisierung“²⁷ fragenden Debatten haben frühzeitig ergeben, dass sich unter dem Blickwinkel der Staatsaufgaben prinzipiell keine Aufgabenfelder bestimmen lassen, die Privatisierungsmaßnahmen völlig entzogenen wären. Vielmehr ist der Aufgabenbestand des Staates „verfassungsrechtlich grundsätzlich offen“²⁸. In Deutschland orientiert man sich an einem formalen Staatsaufgabenbegriff²⁹, wonach staatliche Aufgaben diejenigen öffentlichen Aufgaben³⁰ sind, die der Staat und die ihm zugerechneten Organisationseinheiten auf Grund rechtlicher Zuweisung oder in sonst rechtlich zulässiger Weise wahrnehmen³¹.

Dieses Verständnis eröffnet beträchtliches Privatisierungspotential, das auch Bereiche erfasst, die als „besonders sensible Privatisierungskandidaten“³² gelten. Ein Musterbeispiel ist der Sicherheitssektor, der keineswegs nur eine Staatsaufgabe betrifft und zudem, gegebenenfalls in abgestufter Verantwortung, die Einbindung

27 Vgl. etwa *Hengstschläger* (Fn. 3), S. 174 ff.; zu vielfach als privatisierungsresistent eingestuften zentralen Ordnungsaufgaben (Bundeswehr, Polizei- und Ordnungsverwaltung, Justizverwaltung und Strafvollzug, Finanzverwaltung) siehe *Helmuth Schulze-Fielitz*, Grundmodi der Aufgabenwahrnehmung, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), *Grundlagen des Verwaltungsrechts*, Bd. I, 2006, § 12 Rn. 95 unter Hinweis auf nicht privatisierungsresistente Randbereiche.

28 *Osterloh* (Fn. 3), S. 207; ähnlich bereits *Ossenbühl* (Fn. 3), S. 153. Zu unterschiedlich ansetzenden Versuchen, einen Bestand von notwendigen, nicht der Privatisierung zugänglichen Staatsaufgaben materiell zu bestimmen, siehe aus etwa der Habilitationsliteratur *Gramm* (Fn. 2), S. 23 ff., und *Weiß* (Fn. 2), S. 53 ff.; dazu kritisch *Burgi* (Fn. 23), § 75 Rn. 2.

29 BVerfGE 12, 205 (243); aus der Literatur etwa *Burgi* (Fn. 2), S. 41 ff.

30 Als öffentliche Aufgaben gelten die Aufgaben, „an deren Erfüllung ein gesteigertes Interesse der Gemeinschaft besteht“ (BVerfGE 38, 281 [299]).

31 Vgl. *Burgi* (Fn. 23), § 75 Rn. 2; *Schoch* (Fn. 5), S. 96; und speziell für Verwaltungsaufgaben *Bauer* (Fn. 3), S. 249 f.

32 *Stober* (Fn. 22), S. 2301.

Privater in die Gewährleistung der Inneren Sicherheit nicht ausschließt³³ – so bei der Bewachung von Objekten, bei der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs usw. Ähnlich verhält es sich mit gelegentlich dem staatlichen Vorbehaltsbereich zugeordneten Aufgaben der Daseinsvorsorge³⁴. In diesem Segment ist etwa der Vorstoß des Bundesverwaltungsgerichts, die Erfüllung wasserwirtschaftlicher Aufgaben, bei denen es „um die Wahrung von derart bedeutsamen Gemeinwohlbelangen wie den Erhalt und den Schutz des Wassers – des Oberflächenwassers wie des Grundwassers – für eine ganze Region“ geht, als „lebensnotwendige und letztlich auch nicht ‚privatisierbare‘ Staatsaufgabe“ einzustufen³⁵, beim Bundesverfassungsgericht³⁶ gescheitert. Die Beispiele zeigen, dass sich generalisierende Aussagen zur Privatisierungsresistenz ganzer Rechtsgebiete verbieten; statt dessen ist in der Praxis für die Beurteilung konkreter Privatisierungsvorhaben regelmäßig eine differenzierende Interpretation der jeweils einschlägigen Normen angezeigt.

Dementsprechend waren und sind teilweise noch immer Privatisierungsbestrebungen in vielen Aufgabenfeldern präsent, mit denen die Bevölkerung nahezu täglich in Berührung kommt³⁷: Post, Telekommunikation, Flugsicherung, Bahn, Krankenhauswesen, Strafvollzug, Gerichtsvollzieherwesen, Abfallentsorgung, Abwasser-

33 Dazu *Stober* (Fn. 22), S. 2301 ff., m.w.N. und mit zahlreichen Beispielen namentlich zur Einschaltung privater Sicherheitsdienste in Sicherheitsaufgaben.

34 *Burgi* (Fn. 23), § 75 Rn. 11.

35 BVerwGE 106, 64 (77).

36 BVerfGE 107, 59 (93 f.) mit ergänzendem Hinweis auf ähnlich wichtige Aufgaben wie die Abfallwirtschaft und die Energieversorgung.

37 Aktueller Überblick bei *Schoch* (Fn. 5), S. 97 f.; zu den von der Anfang der 1990er Jahre einsetzenden Privatisierungswelle erfassten Gebieten bei *Bauer* (Fn. 3), S. 245 ff.; jeweils m.w.N.

beseitigung, Wasserversorgung, Energieversorgung, soziale und kulturelle Einrichtungen (Kindergärten, Schwimmbäder, Theater usw.), Messen, Märkte und Volksfeste und auch die Gefahrenabwehr.

2. Privatisierungsmotive

Die mit Privatisierungen verbundenen Erwartungen sind vielfältig. Anlässlich des Erfurter Juristentages wurden diese Erwartungen mit den dazugehörigen Befürchtungen nochmals zusammenfassend präsentiert³⁸. In schlagwortartiger Verkürzung sind danach neben ordnungspolitischen Erwägungen als Privatisierungsmotive vor allem zu nennen: die Nutzung und Einbeziehung privaten Sachverstands, privater Initiative, privaten Verwaltungspotentials und privaten Kapitals, auf anderen Wegen zu erschließende Kapitalquellen und Einsparungen sowie die stärkere Orientierung an Handlungsmustern und Erfolgsstrategien der Privatwirtschaft. Dem stehen allerdings gewichtige Befürchtungen gegenüber; sie reichen von der Nicht- oder Schlechterfüllung, schwindender Gesetzesbindung und reduzierter demokratischer Kontrolle über höhere Kosten für die Leistungsempfänger der Aufgabenbetroffenen als Kehrseite der privaten Gewinnorientierung bis hin zur Gefahr des Entstehens oligo- oder monopolistischer Wirtschaftsstrukturen.

Schon diese kursorische Gegenüberstellung von Pro und Contra zeigt, dass auch rechtspolitisch generalisierende Pauschalaussagen verfehlt wären. Statt dessen sind bei der Entscheidung über konkrete Privatisierungsprojekte jeweils aufgaben-, sach- und situationsbezogene Einzelfallanalysen geboten, auf deren Grundlage die zuständigen Organe

³⁸ *Burgi* (Fn. 4), S. D 24 ff.; vgl. aus noch jüngerer Zeit etwa *Hans J. Wolff/Otto Bachof/Rolf Stober/Winfried Kluth*, Verwaltungsrecht II, 7. Aufl., 2010, § 89 Rn. 30 ff.

im bereichsspezifischen rechtlichen Ordnungsrahmen³⁹ über die Durchführung der Privatisierungsvorhaben zu befinden haben⁴⁰.

III. Privatisierungstypologie, Mischformen, Differenzierungen und Übergänge

1. Typologische Erscheinungsformen

Solche Privatisierungsentscheidungen werden erleichtert⁴¹ durch Typologien, die in der Verwaltungspraxis anzutreffende Privatisierungsphänomene auf typisierte Grundformen zurückführen⁴². Danach lassen sich bei einer an den Privatisierungsgegenständen ansetzenden Differenzierung vier Grundformen unterscheiden, nämlich die

³⁹ Dazu unten nach Fn. 74.

⁴⁰ In diese Richtung bereits frühzeitig *Schoch* (Fn. 9), S. 966 f.; *Bauer* (Fn. 3), S. 258.

⁴¹ Diese Erleichterung wird in den ausufernden Privatisierungsdebatten allerdings relativiert, weil dort immer wieder tatsächlich oder vermeintlich neue Typen zur Diskussion gestellt werden. Abweichend von der sogleich im Text vorgestellten Typologie findet sich in der Privatisierungsdebatte inzwischen auch die Unterscheidung von neun und zehn Privatisierungstypen (vgl. *Burgi* [Fn. 4], S. D 29 m.w.N.). „Spitzenreiter“ dürfte derzeit die Differenzierung zwischen nicht weniger als dreizehn (!) Typen der Privatisierung (*Gregor Kirchhof*, Rechtsfolgen der Privatisierung, AöR 132 [2007], S. 215 [230 f.]) sein.

⁴² Solche Typologien haben längst Eingang in die Lehrbuchliteratur zum Allgemeinen Verwaltungsrecht gefunden – allerdings mit uneinheitlichen Differenzierungen. Die vorliegende Darstellung orientiert sich an der Zusammenstellung bei *Hartmut Maurer*, Allgemeines Verwaltungsrecht, 18. Aufl., 2011, § 23 Rn. 60 ff., die einer in Deutschland verbreiteten Typologie entspricht. Davon abweichend aber beispielsweise *Burgi* (Fn. 4), S. D 32 ff., der einen „neuen Ansatz“ präsentiert und für eine problem- und europarechtsorientierte Typologie mit vier Privatisierungsoptionen ([1] Aufgabenprivatisierung, [2] Public Private Partnerships auf Vertragsbasis und andere Formen der funktionalen Privatisierung, [3] institutionalisierte Public Private Partnerships sowie [4] Beleihung und Akkreditierung zur Konformitätsbewertung) plädiert; kritisch zu diesem Vorschlag *Schoch* (Fn. 5), S. 110 ff.

Vermögensprivatisierung, die Organisationsprivatisierung, die Aufgabenprivatisierung und die sogenannte funktionale Privatisierung. Im Einzelnen:

a) Vermögensprivatisierung

Bei der Vermögensprivatisierung werden Eigentumspositionen und andere Vermögenswerte der öffentlichen Hand, also beispielsweise Grundstücke, Anteilseigentum an Wirtschaftsunternehmen oder auch ganze Industrieunternehmen, an Private übertragen. Die auch mit „Eigentumsprivatisierung“ überschriebene Veräußerung des Tafelsilbers führt der öffentlichen Hand Kapital zu, erschöpft sich dabei aber in einem Einmal-Effekt, weil der jeweilige Vermögenswert nach dem Erwerb durch den Privaten nicht mehr in staatlichem Eigentum steht. Daher wirft die Vermögensprivatisierung auf den ersten Blick „keine besonderen verwaltungsrechtlichen Probleme“ und „insbesondere keine Folgeprobleme“⁴³ auf.

b) Organisationsprivatisierung

Bei der auch „formelle Privatisierung“ genannten Organisationsprivatisierung verbleibt zwar die jeweilige Aufgabe bei dem bisherigen Aufgabenträger (Bund, Land, Kommune usw.). Der Aufgabenträger errichtet aber zur Erledigung der jeweiligen Aufgabe eine privatrechtliche Organisation als Eigengesellschaft⁴⁴. In der

⁴³ Maurer (Fn. 42), § 23 Rn. 64. Bei genauerer Betrachtung der Praxis der Vermögensprivatisierung zeigen sich freilich auch in diesem Privatisierungssegment Folgeprobleme. Das betrifft neben den Fällen der Vermögensteilprivatisierung auch privatisierungsvertraglich angestrebte Sicherungen der Gemeinwohlbindung; vgl. dazu unten III. 2.

⁴⁴ Die sogenannten *Eigengesellschaften* befinden sich ausschließlich in öffentlicher Hand, während an den sogenannten *gemischtwirtschaftlichen Unternehmen* auch

Verwaltungspraxis verbreitete Rechtsformen sind vor allem Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) und Aktiengesellschaften (AG), welche die ihnen zugewiesenen Aufgaben regelmäßig⁴⁵ in privatrechtlichen Handlungsformen erfüllen. Die Organisationsprivatisierung hat der Sache nach im Kommunalrecht eine lange Tradition und im Zuge der Privatisierungswelle namentlich bei der Ver- und Entsorgung (Trinkwasser, Energie, Abwasser, Abfall usw.) zusätzlichen Auftrieb erfahren. Als Vorteile dieser Privatisierungsform gelten die höhere Flexibilität des Privatrechts, die Befreiung von haushaltsrechtlichen und besoldungsrechtlichen Bindungen und Haftungsbegrenzungen⁴⁶.

c) Aufgabenprivatisierung

Bei der auch als „materielle Privatisierung“ bezeichneten Aufgabenprivatisierung zieht sich der Staat, genauer: der bisherige Aufgabenträger (Bund, Land, Kommune usw.), aus der Wahrnehmung einer Aufgabe vollkommen zurück und überlässt diese Aufgabe dem privaten Sektor, den auf dem Markt unter Wettbewerbsbedingungen agierenden privaten Wirtschaftssubjekten. Für Aufgabenprivatisierungen gibt es weite Einsatzfelder, von denen an dieser Stelle aus dem kommunalen Bereich nur exemplarisch der Rückzug aus kulturellen und sozialen Einrichtungen (Theater, Bibliotheken, Kindergärten, Sportstätten usw.) und aus dem Nahverkehr zu erwähnen sind. Damit verbindet sich die Hoffnung auf eine finanzielle Entlastung der

Privatrechtssubjekte als Gesellschafter beteiligt sind; streng genommen sind gemischtwirtschaftliche Unternehmen wegen der Beteiligung privater Gesellschafter freilich bereits eine Mischform.

⁴⁵ Denkbar und in der Praxis anzutreffen sind allerdings auch Konstellationen, in denen das Privatrechtssubjekt auf der Grundlage einer Beleihung mit Hoheitsmacht handelt.

⁴⁶ Maurer (Fn. 42), § 23 Rn. 61.

angespannten öffentlichen Haushalte, daneben teilweise auch die „Erwartung, dass die Aufgabe im freien wirtschaftlichen Wettbewerb besser, effektiver und kostengünstiger erledigt wird“⁴⁷.

d) Funktionale Privatisierung

Bei der bisweilen auch als Erfüllungsprivatisierung⁴⁸ firmierenden funktionalen Privatisierung handelt es sich im Grunde um eine Teilprivatisierung, nämlich um eine Variante der Aufgabenteilprivatisierung. Danach verbleibt die Aufgabe zwar bei dem staatlichen Aufgabenträger (Bund, Land, Kommune usw.), der jedoch in die Aufgabenerledigung einen Privaten einschaltet. Der mehr oder weniger große Teile der Aufgabendurchführung (z. B. Planung, Finanzierung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden, Anlagen, Straßen und ähnlichem) erledigende Privatunternehmer agiert in der Regel als „Verwaltungshelfer“ im privatrechtlichen Rechtsregime⁴⁹. Dafür stehen vielfältigen Modelle von Public Private Partnerships bereit, die in der Vergangenheit große Anziehungskraft ausgeübt haben.⁵⁰ Von solchen Kooperationen verspricht man sich neben finanziellen Einsparungen die Nutzung der Sachkunde, der Eigeninitiative und der Ausstattung privater Unternehmen; Kehrseite davon sind allerdings spezifische und teilweise außerordentlich komplexe Folgeprobleme bei der Absicherung der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung durch den privaten „Erfüllungsgehilfen“. Darauf wird zurückzukommen sein.

⁴⁷ Maurer (Fn. 42), § 23 Rn. 63.

⁴⁸ Dazu und zum Folgenden statt vieler Maurer (Fn. 42), § 23 Rn. 62.

⁴⁹ In Beleihungskonstellationen verfügt der Private über die Hoheitsbefugnisse, mit denen er durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes ausgestattet ist.

⁵⁰ Vgl. dazu und zur Einordnung von Public Private Partnerships in die Kategorie der funktionalen Privatisierung, Peter J. Tettinger, Public Private Partnership, Möglichkeiten und Grenzen – ein Sachstandsbericht, NWVBZ. 2005, S. 1 (1 ff.).

2. Mischformen, Differenzierungen und hybride Übergänge

Die vier Grundformen erleichtern die Orientierung im Privatisierungswildwuchs, haben wegen ihrer idealtypischen Verkürzungen aber gleichwohl nur beschränkten Erkenntniswert. Denn in der Privatisierungspraxis sind häufig Mischformen anzutreffen, weitere Differenzierungen geboten und hybride Übergänge zu verzeichnen. Das kann hier nur exemplarisch verdeutlicht werden.

- Aus empirischer Sicht sind *Vermögensprivatisierungen* keineswegs durchgängig so „unproblematisch“⁵¹, wie dies vordergründig scheinen mag. Abgesehen davon, dass es sich oftmals nur um Teil-Vermögensprivatisierungen handelt⁵² und auch im Übrigen eine Privatisierungsfolgenverantwortung⁵³ fortbestehen kann, finden sich in der Verwaltungspraxis nämlich Konstellationen, in denen die öffentliche Hand mit der Vermögensübertragung weit über die Erzielung eines Veräußerungserlöses hinaus die Sicherstellung beispielsweise sozialer Ziele verknüpft. Ein ebenso anschauliches wie politisch brisantes Beispiel ist die aktuell in eine Schieflage geratene „Dresdner Sozialcharta“, mit der die sächsische Landeshauptstadt Dresden die Sozialverträglichkeit der Privatisierung ihres kommunalen Wohnungsbestandes absichern

⁵¹ Vgl. oben bei Fn. 43.

⁵² Das betrifft insbesondere die Konstellationen, in denen nur Teile eines zunächst hundertprozentigen staatlichen Anteilseigentums veräußert werden und deshalb gemischtwirtschaftliche Unternehmen mit all ihren Steuerungsproblemen im Binnenbereich entstehen (vgl. *Schoch* [Fn. 5], S. 106), aber auch Konstellationen, in denen Organisationsprivatisierungen mit Optionen für spätere (Teil-) Vermögensprivatisierungen verknüpft sind (so ausdrücklich für die Eisenbahnen des Bundes Art. 87 e Abs. 3 GG).

⁵³ *Bauer* (Fn. 3), S. 279; vgl. auch *Burgi* (Fn. 23), § 75 Rn. 3 f., 28 f.

wollte⁵⁴. Die Stadt Dresden hatte 2006 ihre Anteile an der „WOBA Dresden GmbH“ an eine amerikanische Investmentgesellschaft verkauft. Der seinerzeit deutschlandweit für Schlagzeilen sorgende Verkauf brachte rund 982 Millionen Euro in die städtischen Kassen, von denen Dresden einen Großteil zur Tilgung der Schulden des kommunalen Hauhalts einsetzte; die Stadt wurde damit gleichsam „auf einen Schlag“ schuldenfrei. Den Schutz der Mieter der bis dahin städtischen Wohnungen sollte eine in das Vertragswerk mit dem Privatinvestor aufgenommene „Sozialcharta“ gewährleisten⁵⁵.

⁵⁴ Näheres dazu sowie der Stadtratbeschluss vom 22. 9. 2005 zum Verkauf der WOBA Dresden GmbH nebst Sozialcharta ist auf der Internetseite der Stadt Dresden, abrufbar unter http://www.dresden.de/de/02/110/02/verwaltungsgeschichte/08_woba_verkauf.php und http://www.dresden.de/media/pdf/infoblaetter/Beschluss_SR_22_0905_WOBA.pdf, zu finden; siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Woba_Dresden. Zur Kritik und zum „Placebo-Charakter“ der Sozialcharta *Stefan Kofner*, Kommunale Wohnungspolitik, WM 2010, S. 20 (23 ff.).

⁵⁵ Die Sozialcharta enthält neben anderem Regelungen zu sozialen (Punkt 2), städtebaulichen (Punkt 4) und wirtschaftlichen Zielen (Punkt 5) sowie zum Arbeitnehmerschutz (Punkt 3). An erster Stelle steht allerdings der Mieterschutz (Punkt 1). So sollen u.a. die in den bisherigen Mietverträgen zugunsten der Mieter vorgesehenen Regelungen „strikt“ eingehalten und nicht unterlaufen werden; außerdem sollen einzelvertraglich für über 60-jährige Mieter ein lebenslanges Wohnrecht gesichert und Luxussanierungen ausgeschlossen werden. Für Mieterhöhungen in einem Zeitraum von fünf, möglicherweise bis zu zehn Jahren, bestehen Beschränkungen und einzelvertraglich soll ein 10-jähriger Schutz der Mieter vor Eigenbedarfskündigungen und Kündigungen wegen unangemessener wirtschaftlicher Verwertung abgesichert werden. Des Weiteren sieht die Sozialcharta einen Vorrang der sogenannten Mieterprivatisierungen vor Verkäufen an Nichtmieter (Punkt 1.5) vor. Danach ist den Mietern für die zum Verkauf stehende Wohnung zunächst ein um 15% unter dem Marktpreis liegendes Angebot zu unterbreiten. Bei einem Weiterverkauf von Anteilen oder Wohnungsbeständen an Dritte, ist die WOBA GmbH verpflichtet, mit dem neuen Erwerber die Einhaltung der Bedingungen der Sozialcharta vertraglich abzusichern (Punkt 6.2); siehe auch Landeshauptstadt Dresden, Präsentation zum Thema Woba-Verkauf vom 18. 8. 2005, im Internet abrufbar unter http://www.dresden.de/media/pdf/haushalt/presentation_zum_woba_verkauf.pdf; Übersicht über die vertragliche Umsetzung der Regelungen, Vertragsstrafen und andere rechtliche Sicherungen bei *Ralf Lunau*, Dresdner Sozialcharta vertraglich gesichert, Dresdner Blätt'l 4/2006, im Internet abrufbar unter

Doch haben sich die in die „Sozialcharta“ gesetzten Erwartungen offenbar nicht erfüllt, was nicht zuletzt auf Unklarheiten über die dazu in den Privatisierungsvertrag aufgenommenen Vertragsklauseln zurückzuführen sein soll und im Frühjahr dieses Jahres zu einer milliardenschweren Klage gegen den Privatinvestor geführt hat⁵⁶. Hier zeigt sich, dass sich schon der vordergründig einfach erscheinende Vorgang einer Vermögensprivatisierung sehr schnell zu einem komplexen Problem auswachsen kann.

- Ähnlich verhält es sich mit der *Organisationsprivatisierung*, die in der Privatisierungspraxis hochkomplexe Gestaltungen hervorbringt. Musterbeleg ist die Ende der 1990er Jahre durchgeführte

<http://www.dresdnerblaetl.de/2006/04/0701.htm>; zum „Placebo-Charakter“, *Kofner* (Fn. 54), S. 23 ff.

⁵⁶ Presseberichten zufolge betreffen die Unklarheiten insbesondere das Mieter-vorkaufsrecht zum Vorzugspreis, das nach den Privatisierungsverträgen auch an mögliche spätere Käufer inklusive der vereinbarten Strafen weiterzugeben war. Wegen (angeblicher) Nichteinhaltung dieser schuldrechtlichen Vereinbarung hat Dresden unlängst Klage gegen die WOBÄ Südost GmbH und WOBÄ Nordwest GmbH sowie Schiedsklage gegen die WOBÄ Holding GmbH erhoben und die „Heuschrecke“ auf Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von über einer Milliarde Euro verklagt. So sollen Wohnungen verkauft worden sein, ohne sie den Mietern zuvor angeboten zu haben und die aus der Sozialcharta folgenden Verpflichtungen bei Weiterveräußerungen an Dritte nicht weitergegeben worden sein; siehe dazu *Stefan Kofner*, Gagfah: Verfall eines Wohnungsunternehmens, WuM 2011, S. 205 (205 ff.); *Ralf Redemund*, Gagfah will Milliarden-Klage der Stadt vermeiden – vor Gericht droht „fürchterliches Blutbad“, DNN-Online vom 17. 3. 2011, im Internet abrufbar unter <http://www.dnn-online.de/dresden/web/dresden-nachrichten/detail/-/specific/Fristverlaengerung-Gagfah-will-Milliarden-Klage-der-Stadt-vermeiden-1262480155>; Sozialcharta-Klage gegen Gagfah, n-tv online vom 1. 4. 2011, im Internet abrufbar unter: <http://www.n-tv.de/wirtschaft/Dresden-fordert-1-Milliarde-Euro-article2997076.html>; *Peter Schilder*, Häuserkampf in Dresden, F.A.Z. vom 24. 3. 2011, im Internet abrufbar unter <http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/48-000-verkaufte-wohnungen-haeuserkampf-in-dresden-1612925.html>; *Thiemo Heeg*, Der Dresdner Wohnungsstreit eskaliert, F.A.Z. vom 13. 6. 2011, im Internet abrufbar unter: <http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/immobilienunternehmen-gagfah-der-dresdner-wohnungsstreit-eskaliert-13102.html>.

Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe⁵⁷. Die Berliner Wasserbetriebe waren eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, der die Aufgaben der Wasserversorgung der Stadt Berlin und der Abwasserentsorgung übertragen war. Bei der Teilprivatisierung wurde diese Anstalt auf gesetzlicher Grundlage mittels eines komplizierten Geflechts privatrechtlicher Verträge im Rahmen eines Holding-Modells so in einen privatrechtlichen Konzern eingebunden, dass die Holding Aktiengesellschaft mit bis zu 49.9 % am Unternehmen der Anstalt beteiligt, während die restlichen 50.1 % beim Land verbleiben. Der „Modellfall Berliner Wasserbetriebe“⁵⁸ war wiederholt Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen, die neben anderem das schwer durchschaubare Vertragsgeflecht und insbesondere die verfassungsdirigierte Vertragsgestaltung⁵⁹ betrafen.

⁵⁷ Die mit der Teilprivatisierung eingeleitete Umstrukturierung der Wasserwirtschaft in Berlin war wiederholt Anlass für Streitigkeiten vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin (VerfGH, NVwZ 2000, S. 794 (794 ff.); ferner Beschluss vom 21. 10. 1999, VerfGH 71/99; Urteil vom 6. 10. 2009, VerfGH 63/08; Urteil vom 14. 7. 2010, VerfGH 57/08; zitiert nach juris) und ist bis heute Gegenstand öffentlichkeitswirksamer Kontroversen geblieben; zu Stellungnahmen aus der Literatur siehe *Benedikt Wolfers*, Privatisierung unter Wahrung der öffentlich-rechtlichen Rechtsform: Der Modellfall Berliner Wasserbetriebe, NVwZ 2000, S. 765 (765 ff.); *Jan Hecker*, Privatisierung unternehmenstragender Anstalten des öffentlichen Rechts, VerwArch 92 (2001), S. 261 (261 ff.); *Arndt Schmehl*, Teilprivatisierung der Daseinsvorsorge, Demokratieprinzip und Gewinnerzielungsmaxime – BerlVerfGH, NVwZ 2000, 794, JuS 2001, S. 233 (233 ff.).

⁵⁸ *Wolfers* (Fn. 57), S. 765.

⁵⁹ Vgl. VerfGH Berlin, NVwZ 2000, S. 794 (796), wonach der durch das Demokratieprinzip gebotene Einfluss des Landes Berlin bei Weisungen nur dann gewährleistet ist, „wenn im Rahmen der konkreten Ausgestaltung des Unternehmensvertrages das erforderliche Maß an demokratischer Legitimation der Entscheidung gewahrt wird.“

- Auch im Segment der *Aufgabenprivatisierung* dominieren Teil-Privatisierungen⁶⁰: „Nur selten werden – vor allem im kommunalen Bereich – ganze Aufgabengebiete vom öffentlichen in den privaten Sektor verlagert“⁶¹. Dies gilt nicht zuletzt für die heute in vielen Bereichen verbreiteten Public Private Partnerships, bei denen die öffentlichen Aufgabenträger (Bund, Land, Kommune usw.) schon definitionsgemäß präsent bleiben⁶². Die variantenreichen Kooperationsmodelle⁶³ stützen sich zumeist auf vertragliche Grundlagen und Kombinationen von Vertragstypen, deren Gestaltung in der Privatisierungspraxis beträchtliche Probleme aufwerfen kann.

Die Beispiele relativieren die Aussagekraft der Privatisierungstypologie und veranschaulichen zugleich die Komplexität von Privatisierungsvorgängen. Nicht nur am Rande bemerkenswert ist allerdings schon an dieser Stelle, dass bei aller Unterschiedlichkeit des Gegenstandes sämtliche vorgestellten Beispiele am Ende auf einen gemeinsamen archimedischen Problempunkt zulaufen, nämlich auf das Vertragsdesign, auf die vertragliche Gestaltung und Begleitung von Privatisierungsvorgängen.

⁶⁰ Diese Einschätzung hängt freilich in gewissem Umfang von dem mehr oder weniger weiten Zuschnitt der einzelnen Aufgabenbereiche ab.

⁶¹ Schoch (Fn. 5), S. 105 mit ergänzendem Hinweis darauf, dass auch die Aufgabenprivatisierung „weithin durch Teil-Privatisierungen gekennzeichnet“ ist.

⁶² Siehe dazu und zum Folgenden vorerst nur Bauer (Fn. 13), § 36 Rn. 42 ff.

⁶³ Vgl. etwa Peter J. Tettinger, Die rechtliche Ausgestaltung von Public Private Partnership, DÖV 1996, S. 764 (764 ff.); Tettinger (Fn. 50), S. 1 ff.

IV. Stellschrauben zur normativen Steuerung von Privatisierungsprozessen

1. Privatisierung als Prozess

Zur sachgerechten Strukturierung der normativen Steuerung⁶⁴ von Privatisierungsvorgängen hat es sich als hilfreich erwiesen und eingebürgert⁶⁵, Privatisierung als Prozess⁶⁶ zu begreifen. Die prozedurale Konzeption erweitert nämlich die Perspektive über die lange Zeit zu sehr im Vordergrund stehende Frage nach privatisierungsfähigen Aufgabenfeldern („Ob“ der Privatisierung⁶⁷) hinaus auf die Modalitäten („Wie“) der Privatisierung und die in mehreren Phasen ablaufenden Privatisierungsvorgänge. Danach sind wenigstens drei Entwicklungsstadien gesondert zu betrachten, nämlich die Phasen der Vorbereitung von Privatisierungen, der eigentlichen Privatisierungsentscheidung und der After Privatization.

⁶⁴ Dazu wegweisend für die verwaltungsrechtliche Diskussion *Gunnar Folke Schuppert*, Verwaltungsrechtswissenschaft als Steuerungswissenschaft, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Schuppert (Hrsg.), Reform des Allgemeinen Verwaltungsrechts: Grundfragen, 1993, S. 65 (65 ff.); zu der Debatte auf der Freiburger Staatsrechtslehrertagung über die inzwischen übertriebene, weil viel zu vereinseitigende Deutung der Verwaltungsrechtswissenschaft als Steuerungswissenschaft vgl. die Berichte von *Ivo Appel* und *Martin Eifert* zum dritten Beratungsgegenstand „Das Verwaltungsrecht zwischen klassischem dogmatischem Verständnis und steuerungswissenschaftlichem Anspruch“ mit anschließender Diskussion in VVDStRL 67 (2008), S. 226 ff., 286 ff., 334 ff.; vgl. ferner bereits die Berichte von *Matthias Schmidt-Preuß* und *Udo Di Fabio* auf der Dresdner Staatsrechtslehrertagung zum Berichtsgegenstand „Verwaltung und Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher Steuerung“ in VVDStRL 56 (1997), S. 160 ff., 235 ff.

⁶⁵ Vgl. nur *Schröder* (Fn. 25), S. 152.

⁶⁶ Zu diesem Vorschlag *Bauer* (Fn. 3), S. 254.

⁶⁷ Damit ist das „Ob“ der Privatisierungsfähigkeit angesprochen, das sich zuallererst für der Privatisierung zugängliche und privatisierungsresistente Aufgaben, also für Privatisierungsoptionen und deren Grenzen interessiert; vgl. oben bei Fn. 27.

2. Ausgewählte normative Steuerungsansätze

In der Gesamtbetrachtung greifen bei der normativen Steuerung von Privatisierungsprozessen zahlreiche Vorschriften aller Rechtsebenen ineinander: Völkerrecht, Europarecht⁶⁸, nationales Verfassungs- und Verwaltungsrecht von Bund und Ländern, außerdem zivil- und strafrechtliche Regelungsmaterien. Das zwingt zur Beschränkung auf einige ausgewählte Steuerungsansätze.

Die normative Steuerung kann bereits im Vorfeld der Entscheidung über das „Ob“ einer Privatisierung ansetzen und die Verwaltung in die Richtung hin zu einer Privatisierung dirigieren. So verpflichten in Deutschland haushaltsrechtliche Vorschriften⁶⁹ schon im weit vorgelagerten Vorfeld von etwaigen Privatisierungsentscheidungen aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zur „Prüfung, inwieweit staatliche Aufgaben oder öffentlichen Zwecken dienende wirtschaftliche Tätigkeiten durch Ausgliederung und Entstaatlichung oder Privatisierung erfüllt werden können.“ Von diesen Prüfpflichten und Darlegungslasten geht in einer frühen *Phase der Entscheidungsfindung* ein gewisser Privatisierungsdruck aus, auch wenn sich damit noch keine konkreten Privatisierungspflichten verbinden. In abgeschwächter Form finden sich solche Privatisierungsimpulse auch im Fachrecht, wenn der Gesetzgeber die rechtlich ohnehin gegebene Option einer Kooperation mit Privaten

⁶⁸ Speziell zum Europarecht findet sich zwar bis heute mitunter die Bemerkung, dass es sich streng „juristisch gesehen [...] zu mitgliedstaatlichen Privatisierungsvorgängen als solchen indifferent“ verhalte (vgl. *Schoch* [Fn. 5], S. 111). Doch haben eingehendere Untersuchungen längst nachgewiesen, dass Privatisierungsvorgänge auch gemeinschafts- bzw. unionsrechtlichen Bindungen unterliegen und den Anforderungen und Direktiven der Grundfreiheiten sowie des europäischen Beihilfe- und Vergaberechts genügen müssen (vgl. aus jüngerer Zeit statt vieler *von Danwitz* (Fn. 4), S. M 27 ff.

⁶⁹ Fn. 24.

nur deklaratorisch ausdrücklich hervorhebt und damit die Verwaltung zu einem Nachdenken über die Begründung einer Öffentlich Privaten Partnerschaft inspiriert und stimuliert⁷⁰.

Normative Direktiven gibt es auch für die eigentliche *Privatisierungsentscheidung*⁷¹. Dazu zählen zunächst Privatisierungsgebote, für die das Grundgesetz zwar prominente Beispiele in den Vorschriften über Post und Bahn liefert⁷², sich aber im Übrigen mit allgemeingültigen Aussagen zurückhält. Wenig ergiebig ist der Verfassungstext auch bei der Suche nach Privatisierungsverboten. Obschon sich namentlich das Staatsorganisationsrecht alles andere als privatisierungsneutral verhält, setzt sich zunehmend die Auffassung durch, dass das Grundgesetz jenseits eines wie auch immer näher zu bestimmenden „Kernbereichs des staatlichen Gewaltmonopols kaum absolute Privatisierungsverbote kennt“⁷³. Das gilt auch für die kommunale Selbstverwaltungsgarantie⁷⁴, schließt aber verfassungs-

70 So § 56 Satz 3 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG), wonach sich die zur Abwasserbeseitigung verpflichteten Kommunen „zur Erfüllung ihrer Pflichten Dritter bedienen“ können. Zu den Regelungsintentionen der in dem hier interessierenden Zusammenhang gleichlautenden Vorläufernorm siehe *Hartmut Bauer*, Privatisierungsimpulse und Privatisierungspraxis in der Abwasserentsorgung – Eine Zwischenbilanz, *VerwArch* 90 (1999), S. 561 (563 ff.).

71 Vgl. etwa *Burgi* (Fn. 4), S. D 52 ff.

72 Art. 87 e Abs. 3, 143 Abs. 1 GG.

73 *Schröder* (Fn. 25), S. 155 f.

74 Insbesondere kann der Versuch, das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht als verfassungsrechtliches Verbot für die Privatisierung eines (dem Bereich der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben zuzuordnenden) „traditionell bedeutsamen“ Weihnachtsmarktes zu instrumentalisieren (BVerwG, BayVBl. 2010, S. 376 [376 ff.]), nicht überzeugen; zur Kritik siehe statt vieler *Friedrich Schoch*, Das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht gemäß Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG als Privatisierungsverbot?, *DVBbl.* 2009, S. 1533 (1533 ff.). Bei kommunalen Pflichtaufgaben scheidet zwar eine Aufgabenvollprivatisierung aus; zulässig ist jedoch auch in diesem Bereich Teilprivatisierung etwa durch die Einbeziehung Privater in die Aufgabenerledigung.

rechtliche Anforderungen an die Modalitäten, das „Wie“ von Privatisierungen nicht aus. Im Übrigen enthalten regelmäßig die Fachgesetze des Besonderen Verwaltungsrechts spezielle Regelungen, die über den konkreten Aufgabenumfang und bereichsspezifisches Privatisierungspotential informieren⁷⁵. Mit hierher gehören auch die normativen Subsidiaritätsklauseln für die wirtschaftliche Betätigung von Kommunen, die schon in der Vergangenheit zu zentralen Stellschrauben für die gesetzgeberische Steuerung von Privatisierungs- und Rekommunalisierungsprozessen herangewachsen sind und aktuell erneut dafür eingesetzt werden⁷⁶.

⁷⁵ Das macht (bisweilen ebenenübergreifende) Detailanalysen der einschlägigen Gesetze erforderlich; siehe etwa zu Optionen der Teil- und Vollprivatisierung im Abwasserrecht *Bauer* (Fn. 13), § 36 Rn. 124 f.

⁷⁶ Das Subsidiaritätsprinzip ist neben anderen Voraussetzungen eine weitere Anforderung an die wirtschaftliche Betätigung der Kommune. Danach darf sich die Kommune wirtschaftlich betätigen, wenn sie die Aufgabe besser erfüllen kann als ein Privater. Kann ein Privater die Aufgabe allerdings kostengünstiger erfüllen, so gebührt ihm grundsätzlich ein Vorrang und die Aufgabe soll an diesen abgegeben werden. Können der Private und die Kommune die Aufgabe gleich gut erfüllen, hängt die Zulässigkeit der kommunalen wirtschaftlichen Betätigung davon ab, ob die jeweiligen kommunalwirtschaftlichen Regelungen echte oder unechte Subsidiaritätsklauseln enthalten. Bei ersterer darf die Aufgabe nicht „ebenso gut und wirtschaftlich durch einen anderen erfüllt“ werden können, d.h. die Gemeinde muss im Vergleich zum privaten Leistungserbringer Effizienzvorteile vorweisen (z.B. in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen [§ 102 Abs. 1 Nr. 3 GO BW, Art. 87 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BayGO, § 91 Abs. 3 BbgKVerf, § 121 Abs. 1 Nr. 3 HessGO, § 68 Abs. 2 Nr. 3 KV MV, § 136 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 NiedersKomVG, § 85 Abs. 1 Nr. 3 GO RP, § 108 Abs. 1 Nr. 3 SaarlKSVG, § 71 Abs. 1 Nr. 4 ThürKO]). Im Fall der Leistungsparität soll die Aufnahme der wirtschaftlichen Betätigung der Kommune demnach unterbleiben, sofern keine anderweitigen Ausnahmen vom Privatisierungsgebot bestehen. Sinn und Zweck dieser „verschärften“ Subsidiaritätsklausel ist es, die wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand einzuschränken und den Vorrang der privaten Leistungserbringung zu betonen, vgl. NRW LT-Drucks. 14/3979, S. 2, 149; BW LT-Drucks. 12/5615, S. 18. Ein Vorrang der Privatwirtschaft im Fall der Leistungsparität ist hingegen abzulehnen, wenn eine unechte Subsidiaritätsklausel vorliegt, d.h. der Zweck „nicht besser oder wirtschaft-

Neben der hier nicht zu vertiefenden Phase der Aufgabenübertragung⁷⁷ ist ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt für die normative Steuerung die *Phase nach der Privatisierung*, in der staatliche Aufgabenverantwortung fortbestehen kann. In der Hervorhebung dieses

licher“ durch einen Privaten erfüllt werden kann (z.B. Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein [§ 107 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW, § 97 Abs. 1 Nr. 3 SächsGO, § 116 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GO LSA, § 101 Abs. 1 Nr. 3 GO SH]). Hintergrund dieser „einfachen“ Subsidiaritätsregelung ist das Anliegen, die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde zu stärken, da diese „seit jeher das Wesen der kommunalen Selbstverwaltung“ geprägt hat und „typusbestimmend“ sei, vgl. BW LT-Drucks. 12/4055, S. 23 f. In jüngerer Zeit spielt dies in Brandenburg eine Rolle. Der Landtag Brandenburg hat sich am 20. 1. 2010 zu einer öffentlichen Daseinsvorsorge durch die Kommunen bekannt und die Landesregierung aufgefordert, die dazu erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, vgl. Bbg LT-Drucks. 5/332-B. Durch das „Gesetz zur Stärkung der kommunalen Daseinsvorsorge“ sollen unnötige Hemmnisse, die u.a. durch das verschärfte Subsidiaritätsprinzip des § 91 Abs. 3 BbgKVerf entstehen, beseitigt werden und die Möglichkeit für eine kommunale wirtschaftliche Betätigung ausgeweitet werden. Die wirtschaftliche Betätigung der Kommune sei wesentlicher Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie und garantiert den Kommunen die eigenverantwortliche Erledigung ihrer Aufgaben, d.h. die Entscheidung über das „Ob“ und „Wie“ der Aufgabenerfüllung. Ein Nachrang der öffentlichen Hand gegenüber den Privaten sei insofern nicht sachgerecht; näheres dazu Bbg LT-Drucks. 5/3023. Die Subsidiaritätsklausel scheint für manche Regierungsparteien zudem eine beliebte Stellschraube für die Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde zu sein. Dies zeigt ein Vergleich der Subsidiaritätsregelungen in Nordrhein-Westfalen. In Zeiten einer roten oder rot-grünen Regierung gibt es keinen Vorrang der Privatwirtschaft, sodass § 107 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW in der Fassung bis zum 16. 10. 2007 eine unechte Subsidiaritätsklausel enthielt. Im Jahre 2005 kam es zum schwarz-gelben Machtwechsel und damit auch zur Änderung der Subsidiaritätsklausel. Mit dem „Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung - GO- Reformgesetz“ aus dem Jahr 2007 wurde die verschärfte echte Subsidiaritätsklausel eingeführt, vgl. LT-Drucks. 14/3939, 14/4981. Diese sollte allerdings nicht lange währen. Der rot-grüne Machtwechsel im Jahre 2010 führte u.a. zu dem „Gesetz zur Revitalisierung des Gemeindewirtschaftsrechts“, durch das das Gemeindewirtschaftsrecht in §107 GO NRW wieder auf den Stand vor der Gesetzesänderung im Jahr 2007 mit seiner unechten Subsidiaritätsklausel gebracht wurde, vgl. LT-Drucks. 15/27, 15/867.

⁷⁷ Dazu etwa *Bauer* (Fn. 3), S. 272 ff.; *Schröder* (Fn. 25), S. 155 f; *Burgi* (Fn. 4), S. D 92 ff.

Aspekts liegt ein wesentlicher Ertrag der prozessorientierten Analyse⁷⁸ von Privatisierungsvorgängen. Inzwischen haben die jahrelangen Debatten nämlich geklärt, dass Privatisierungen nicht notwendig in einen vollständigen Rückzug des Staates münden. Vielmehr bleibt eine staatliche Verantwortung für das Gemeinwesen erhalten, trifft den Staat in vielen Bereichen zumindest eine Gewährleistungspflicht für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung⁷⁹, die bereichsspezifischer Differenzierung zugänglich und zudem regelmäßig einfachgesetzlicher Konkretisierung bedürftig ist. Im neuen Post- und Eisenbahnverfassungsrecht ist diese Gewährleistungspflicht sogar ausdrücklich geregelt⁸⁰, im Übrigen lässt sich die staatliche Verpflichtung zur Sicherstellung des lebenswichtigen Bedarfs der Bevölkerung auf Verfassungsprinzipien und grundrechtliche Schutzpflichten zurückführen, wobei es in allen Bereichen – wie erwähnt – regelmäßig einer einfachgesetzlichen Konkretisierung⁸¹ oder auch einer rechtsdirigierten Gestaltung durch die beteiligten Akteure bedarf. Das macht die Umsetzung der normativen Direktiven in der Rechtspraxis zu einem ausgesprochen „schwierigen Geschäft“.

⁷⁸ Oben IV. 1.

⁷⁹ Siehe dazu aus den Anfängen der aktuellen Privatisierungswelle *Bauer* (Fn. 3), S. 268 ff., 274 ff., 277 ff. m.w.N. aus der älteren Literatur und aus der jüngeren Diskussion *Burgi* (Fn. 4), S. D 94 ff. m.w.N.

⁸⁰ Art. 87 e Abs. 4, 87 f Abs. 1 GG.

⁸¹ Das gilt für die beiden in Fn. 80 erwähnten Prototypen schon von Verfassungen wegen. Siehe im Übrigen allgemein zu Begründung und Konturen von Sicherstellungsaufträgen und deren prinzipielles Angewiesensein auf gesetzgeberische Ausgestaltung *Hermann Butzer*, Sicherstellungsaufträge, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), *Handbuch des Staatsrechts (HStR)*, Bd. IV, 3. Aufl., 2006, § 74 Rn. 23 ff., 38 ff. mit Hinweisen auch zur europarechtlichen Abstützung.

V. Ansatzpunkte zur dogmatisch-systematischen Erfassung rechtlich gestalteter Privatisierungswirklichkeit

1. Verwaltungsrechtswissenschaftliche Innovationsimpulse

Der Umgang mit diesen Schwierigkeiten fällt auch der Verwaltungsrechtswissenschaft nicht leicht. Sie hat erkennbar Probleme bei der dogmatisch-systematischen Erfassung der rechtlich gestalteten Privatisierungswirklichkeit. Für deren Bewältigung scheint manchen die zwar von dem traditionsreichen Dogmenbestand und bewährten Erfahrungsschatz ausgehende, aber längst in vielerlei Hinsicht fortentwickelte moderne Verwaltungsrechtslehre nicht mehr hinreichend leistungsfähig zu sein. Auf Auswege aus dem tatsächlich oder vermeintlich zu eng gewordenen Korsett klassischen Verwaltungsrechtsdenkens sollen Schlüsselbegriffe⁸² verweisen, die mitunter freilich nicht mehr als catch words sind und sich deshalb allenfalls für Arrangements in einer patch work-Systematik eignen.

Gewiss: „Infrastrukturverwaltungsrecht“⁸³, „Privatisierungsfolgenrecht“⁸⁴, „Verwaltungsgesellschaftsrecht“⁸⁵, „Verwaltungskooperations-

82 Vgl. *Andreas Voßkuhle*, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. I, 2006, § 1 Rn. 40 f.

83 Vgl. *Heiko Faber*, Verwaltungsrecht, 3. Aufl., 1992; *Georg Hermes*, Staatliche Infrastrukturverantwortung, 1998.

84 Vgl. *Bauer* (Fn. 3), S. 279 (Privatisierungsfolgenverantwortung); *Jörn Axel Kämmerer*, Verfassungsstaat auf Diät?, JZ 1996, S. 1042 (1047 ff.); *Kämmerer* (Fn. 1), S. 423 ff.; *Martin Burgi*, Kommunales Privatisierungsfolgenrecht: Vergabe, Regulierung und Finanzierung, NVwZ 2001, S. 601 (601 ff.).

85 Begriffsprägend *Ernst Thomas Kraft*, Das Verwaltungsgesellschaftsrecht, 1982; aus jüngerer Zeit etwa *Thomas von Danwitz*, Vom Verwaltungsprivat- zum Verwaltungsgesellschaftsrecht, AöR 120 (1995), S. 595 (595 ff.); *Walter Krebs*,

recht“⁸⁶, „Gewährleistungsverwaltungsrecht“⁸⁷, „Ausschreibungsverwaltungsrecht“⁸⁸, „Regulierungsverwaltungsrecht“⁸⁹ und vielleicht auch „Dienstleistungsverwaltungsrecht“⁹⁰ sind Chiffren, die auf mögliche Innovationsbedarfe verweisen und mit den dazugehörigen Staatsbildern („kooperativer Staat“⁹¹, „Regulierungsstaat“⁹², „Gewährleistungsstaat“⁹³, „Dienstleistungsstaat“⁹⁴) hohe Suggestivkraft ausüben. Zusammen mit anderen Modernisierungsimpulsen mögen

Notwendigkeit und Struktur eines Verwaltungsgesellschaftsrechts, *Die Verwaltung* 29 (1996), S. 309 (309 ff.); kritisch *Thomas Mann*, *Die öffentlich-rechtliche Gesellschaft*, 2002, insbesondere S. 269 ff.; *Thomas Mann*, Kritik am Konzept des Verwaltungsgesellschaftsrechts, *Die Verwaltung* 35 (2002), S. 463 (463 ff.).

86 *Gunnar Folke Schuppert*, Jenseits von Privatisierung und „schlankem“ Staat: Vorüberlegungen zu einem Konzept der Staatsentlastung durch Verantwortungsteilung, in: *Gusy* (Hrsg.), *Privatisierung von Staatsaufgaben: Kriterien – Grenzen – Folgen*, 1998, S. 72 (111 f.); *Hartmut Bauer*, Zur notwendigen Entwicklung eines Verwaltungskooperationsrechts – Statement, in: *Schuppert* (Hrsg.), *Jenseits von Privatisierung und „schlankem“ Staat*, 1999, S. 251 (251 ff.).

87 *Voßkuhle* (Fn. 3), S. 307 ff.; *Friedrich Schoch*, Gewährleistungsverwaltung: Stärkung der Privatrechtsgesellschaft?, *NVwZ* 2008, S. 241 (241 ff.); *Burgi* (Fn. 4), S. D 101 ff.

88 *Burgi* (Fn. 4), S. D 102.

89 Z.B. *Matthias Ruffert*, *Regulierung im System des Verwaltungsrechts*, *AöR* 124 (1999), S. 237 (237 ff.); *Johannes Masing*, Stand und Entwicklungstendenzen eines Regulierungsverwaltungsrechts, in: *Bauer/Huber/Niewiadomski* (Hrsg.), *Ius Publicum Europaeum*, 2002, S. 161 (161 ff.); *Johannes Masing*, Soll das Recht der Regulierungsverwaltung übergreifend geregelt werden?, Gutachten D für den 66. Deutschen Juristentag, 2006; *Michael Fehling/Matthias Ruffert* (Hrsg.), *Regulierungsrecht*, 2010.

90 *Franz Reimer*, *Qualitätssicherung, Grundlagen eines Dienstleistungsverwaltungsrechts*, 2010.

91 Begriffsprägend *Ernst-Hasso Ritter*, *Der kooperative Staat*, *AöR* 104 (1979), S. 389 (389 ff.).

92 Vgl. frühzeitig *Edgar Grande*, *Entlastung des Staates durch Liberalisierung und Privatisierung?*, in: *Vogt* (Hrsg.), *Abschied vom Staat – Rückkehr zum Staat?*, 1993, S. 371 (388 f.); später etwa *Gunnar Folke Schuppert*, *Verwaltungswissenschaft*, 2000, S. 383.

93 Z.B. *Matthias Knauff*, *Der Gewährleistungsstaat: Reform der Daseinsvorsorge*, 2004.

94 *Andreas Voßkuhle*, *Der „Dienstleistungsstaat“: Über Nutzen und Gefahren von Staatsbildern*, *Der Staat* 40 (2001), S. 495 (495 ff.).

solche Suggestionen vordergründig die Proklamation der „Neuen Verwaltungswissenschaft“ unterstützen, die „zu einer Zäsur in der Arbeit am Verwaltungsrecht“⁹⁵ geführt haben soll.

Indes stehen die erwähnten Stichworte ganz überwiegend nicht für hinreichend detailliert verdichtete dogmatische Konzepte, die system(um)prägende Kraft für das Allgemeine Verwaltungsrecht entfalten oder gar die Forderung nach einer „Neuen Verwaltungswissenschaft“ rechtfertigen, geschweige denn einlösen könnten⁹⁶. Oftmals verbinden Autoren mit ihren „Schlüsselbegriffen“ denn auch viel zurückhaltendere Anliegen, so etwa mit dem Dienstleistungsverwaltungsrecht im Ansatz vornehmlich heuristische Funktionen⁹⁷, mit dem Regulierungsverwaltungsrecht nur bereichsspezifische Teildogmatiken⁹⁸ und mit dem Ausschreibungsverwaltungsrecht die stärkere Akzentuierung eines konventionellen, im Zuge der Privatisierung strukturell fortentwickelten Verwaltungsrechtsgebiets mit

⁹⁵ Voßkuhle (Fn. 82), § 1 Rn. 1, 71.

⁹⁶ Mit voller Berechtigung sieht sich die „Neue Verwaltungsrechtswissenschaft“ der Frage ausgesetzt, was an ihr wirklich „neu“ ist (siehe nur den treffenden Untertitel der Rezension von Jörn Ipsen, Grundlagen des Verwaltungsrechts. Ein großer Bestand an Altem im vorgeblich Neuen, Die Verwaltung 44 [2011], S. 290 [290 ff.]: „Ein großer Bestand an Altem im Vorgeblich Neuen“; ähnlich die Gesamtwürdigung in der Rezension von Christian Starck, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft?, JZ 2010, S. 1170 [1173]: „Keine neue Verwaltungsrechtswissenschaft“), zumal sie mit ihrem einseitig verabsolutierten Steuerungsansatz zentrale Arbeitsfelder moderner und zeitgemäßer Verwaltungsrechtswissenschaft wie etwa die Rechtsverhältnislehre völlig vernachlässigt (dazu vollkommen berechtigte Kritik bei Ipsen, a.a.O., S. 298 f.) und sich auch im Übrigen kritische Rückfragen zur konzeptionellen Gesamtausrichtung gefallen lassen muss (dazu etwa Bauer [Fn. 13], § 36 Rn. 135 ff.); eingehende kritische Durchleuchtung bei Wolfgang Kahl, Über einige Pfade und Tendenzen in Verwaltungsrecht und Verwaltungswissenschaft – Ein Zwischenbericht, Die Verwaltung 42 (2009), S. 463 (463 ff.) m.w.N.

⁹⁷ Vgl. Reimer (Fn. 90), S. 75 und weitergehend S. 421 ff.

⁹⁸ Masing (Fn. 89), S. D 1: „Ein ‚Recht der Regulierungsverwaltung‘ gibt es bisher nicht – jedenfalls nicht als aufeinander bezogene Rechtsmaterie“.

enormem Bedeutungszuwachs⁹⁹, das überdies auch privatisierungsunspezifisches klassisches Beschaffungswesen einschließt¹⁰⁰. Das Infrastrukturverwaltungsrecht konzentriert sich gegenständlich auf den Teilaspekt der Infrastruktur, das Verwaltungsgesellschaftsrecht auf eine begrenzte Auswahl von Organisationsformen und das Privatisierungsfolgenrecht auf einen zeitlich nach der Privatisierung liegenden Ausschnitt von Privatisierungsvorgängen.

Ähnlich verhält es sich mit dem in jüngerer Zeit intensiver erörterten Gewährleistungsverwaltungsrecht, dessen Kerngedanke schon

⁹⁹ Vgl. *Burgi* (Fn. 4), S. D 101 f.

¹⁰⁰ Das klassische Beschaffungswesen hat eine lange Tradition, die bis in das 19. Jahrhundert zurückreicht, und deren Ursprünge noch im heutigen Recht erkennbar sind. Zwar verfolgte das öffentliche Auftragsrecht zunächst nur haushaltsrechtliche Zwecke, um die „korrekte und wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Gelder“ sicherzustellen (BT-Drucks. 13/9340, S. 12). Wenigstens als Reflex der haushaltsrechtlichen Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit hatte das Beschaffungswesen aber seit jeher auch eine wettbewerbliche Funktion. Der Einfluss zahlreicher europarechtlicher Richtlinien hat in den letzten 20 Jahren allerdings zu einer verstärkten Betonung der wettbewerblichen Komponente des Vergaberechts geführt, ohne dass die zugleich haushaltsrechtliche Funktion des Vergaberechts dadurch in Frage gestellt worden wäre. So kam es in der Vergabepraxis durch den stärker betonten Wettbewerb zwischen den potentiellen Auftragnehmern zu einer weiteren deutlichen Absenkung der Preise für öffentliche Aufträge (*Rudolf Weyand*, Praxiskommentar Vergaberecht, 3. Aufl., 2011, GWB Teil 1 Rn. 9). Die aktuelle wirtschaftliche und politische Bedeutung des öffentlichen Beschaffungswesens zeigt sich eindrucksvoll in dem darauf bezogenen EU-weiten jährlichen Geschäftsvolumen von 1.500 Milliarden Euro (16% des BIP der Europäischen Union). Das entspricht mehr als einer Verdopplung der 1998 geschätzten Umsätze (dazu *Weyand*, a.a.O., GWB Teil 1 Rn. 8). Ein wichtiger Teil dieses Geschäftsvolumens folgt aus der Privatisierung öffentlicher Aufgaben (insbesondere durch Öffentlich Private Partnerschaften), die ebenfalls dem Recht der öffentlichen Auftragsvergabe unterliegen kann. Die privatisierungsrelevanten Problemfelder des Vergaberechts betreffen vor allem die Frage, wann eine Privatisierung als öffentliche Auftragsvergabe zu werten ist, welche Verfahrensmöglichkeiten auf dem Weg zur Auftragsvergabe offenstehen (ob etwa ein wettbewerblicher Dialog stattfinden kann), welche Privatisierungsmodelle in Betracht kommen und wie diese Modelle im Einzelfall auszugestalten sind.

seit vielen Jahrzehnten in die wissenschaftliche Diskussion¹⁰¹ eingeführt ist und auch längst die Praxis erreicht hat¹⁰². Nicht nur aus diesem Grund spricht vieles dafür, dass das inhaltlich unsicher gebliebene¹⁰³ Gewährleistungsverwaltungsrecht über weite Strecken nur Altbekanntes in (teilweise¹⁰⁴) neuer begrifflicher Einkleidung aufgreift und dadurch bisweilen eher zur Verwirrung als zur Klärung beiträgt. So ist namentlich das „Neue“ Institut der „Gewährleistungsvereinbarung“¹⁰⁵ bzw. des „Gewährleistungs-vertrags“¹⁰⁶ nichts anderes als der bekannte und bis in den amtlichen Sprachgebrauch hinein geläufige Kooperationsvertrag. Auch in Privatisierungskontexten ist der Kooperationsvertrag begrifflich präziser, weil die „Gewährleistung“

101 Viele Überlegungen aus den aktuellen Debatten über das Gewährleistungsverwaltungsrecht sind bereits thematisiert und bisweilen bis in die Begrifflichkeit hinein (u.a. „Auffangfunktion des Privatrechts“, „Steuerungsverluste“, „Kontrollpflichten“, „Informationspflichten“, „Gewährleistungsformen“ und nicht zuletzt der Schlüsselbegriff der „Garantenstellung“) vorweggenommen bei *Gallwas* (Fn. 3), S. 211 ff., dessen Vorarbeiten erstaunlicherweise viel zu wenig berücksichtigt werden.

102 Siehe nur Sächsische Staatskanzlei, Privatisierungskonzept der Staatsregierung, Sächs LT-Drucks. 1/3524, S. 2: „Aufgabe des Staates ist vor allem die Gewährleistung und nicht so sehr die Erbringung von (Verwaltungs-)Leistungen“.

103 Vgl. nur einerseits *Vofkuhle* (Fn. 3), S. 310 ff., der als „Grundbausteine einer Dogmatik des Gewährleistungsverwaltungsrechts“ Ergebnissicherung, Qualifikation und Auswahl privater Akteure, Schutz der Rechte Dritter, Lenkung und Kontrolle, Evaluation und Lernen sowie effektive staatliche Rückholoptionen ausmacht, und andererseits *Burgi* (Fn. 4), S. D 101 ff., der als „Instrumente der Gewährleistungsverwaltung“ das Vergaberecht, das Vertragsrecht (Gewährleistungsvereinbarung bzw. Gewährleistungsmaßnahmen nach Beleihung/Akkreditierung) und das Gesellschaftsrecht benennt.

104 So sind viele der in Fn. 103 genannten Bausteine und Instrumente bis hin zu Rückholoptionen und Fragen der Vertragsgestaltung schon aus den Debatten auf und im Umfeld der Hallenser Staatsrechtslehrertagung von 1994 bekannt und vertraut, ohne dass ein wesentlicher Erkenntniszuwachs der unter dem Label „Gewährleistungsverwaltung“ geführten Debatten ersichtlich wäre.

105 *Burgi* (Fn. 4), S. D 103 f., 107 ff.

106 *Bernward Wollenschläger*, Effektive staatliche Rückholoptionen bei gesellschaftlicher Schlechterfüllung, 2006, S. 181 (181 ff.).

ordnungsgemäßer Aufgabenerfüllung nur ein Teilaspekt der wesentlich umfassender auf zumeist längerfristige Zusammenarbeit angelegten Verträge ist. Daher trifft die „Neue“ Begrifflichkeit den Vertragsgegenstand nicht wirklich punktgenau. Auch wirkt sie etwas gewollt originell, behindert dadurch die Anschlussfähigkeit an die sachorientierten Überlegungen zur Modernisierung des Verwaltungsvertragsrechts und erscheint zumindest unzweckmäßig. Doch mögen diese und andere Vorbehalte hier auf sich beruhen.

2. Insbesondere: Verwaltungskooperationsrecht

Weiterführender ist die Anregung zur Erarbeitung eines Verwaltungskooperationsrechts¹⁰⁷, die inzwischen sogar gesetzgeberische Aktivitäten ausgelöst hat. Im Fokus des Verwaltungskooperationsrechts steht die kooperative Aufgabenerledigung im verantwortungsteilenden Zusammenwirken von öffentlichen und privaten Rechtsträgern, die zugleich das interessanteste und in der Praxis wohl auch wichtigste Privatisierungssegment ist. Perspektivisch zielt das Verwaltungskooperationsrecht darauf ab, im Querschnitt die sachspezifische Ausformung der Rechtsordnung für den Kooperationsbereich aufzunehmen, zu strukturieren, zu analysieren und

¹⁰⁷ Siehe dazu zunächst die Nachweise in Fn. 86; aufgegriffen, fortgeführt und vertieft insbesondere bei *Schuppert* (Fn. 92), S. 443 ff., und den beiden 2001 im Auftrag des Bundesministeriums des Innern zur Vorbereitung einer Kodifikation erstellten Gutachten von *Gunnar Folke Schuppert*, Grundzüge eines zu entwickelnden Verwaltungskooperationsrechts, Regelungsbedarf und Handlungsoptionen eines Rechtsrahmens für Public Private Partnership. Rechts- und verwaltungswissenschaftliches Gutachten, erstellt im Auftrag des Bundesministeriums des Innern, Juni 2001, und von *Jan Ziekow*, Verankerung verwaltungsrechtlicher Kooperationsverhältnisse (Public Private Partnership) im Verwaltungsverfahrensgesetz. Wissenschaftliches Gutachten, erstattet für das Bundesministerium des Innern, Juni 2001.

zu ordnen¹⁰⁸. Danach ist ein zentraler Kernbereich die vertragliche Zusammenarbeit von Öffentlicher Verwaltung und Privaten. Dementsprechend befasst sich das Verwaltungskooperationsrecht vor allem mit Public Private Partnership-Szenarien, mit einer zeitgemäßen Fortentwicklung des Verwaltungsvertragsrechts und mit der Bereitstellung einer modernen, leistungsfähigen Verwaltungsvertragsrechtslehre¹⁰⁹. Dafür bieten sich zwei Ansatzpunkte an, nämlich zum einen die gesetzliche Regelungsebene und zum anderen die vertragliche Ebene, auf der die Vertragspartner gleichsam im Wege der Selbststeuerung autonom ihre wechselseitigen Rechte und Pflichten festlegen, also bestimmen, was zwischen ihnen rechtens sein soll.

Eine Analyse der *ersten, der gesetzlichen Regelungsebene* hat ergeben, dass der Gesetzgeber Kooperationsbeziehungen vielfach nicht abschließend determiniert. Statt dessen formuliert er oftmals lediglich Ziele, er zeigt Optionen für verantwortungsteilende Aufgabenerledigung oder er begnügt sich auf andere Weise damit, mehr oder weniger intensive rechtliche Direktiven für die Zusammenarbeit zu geben. Im Übrigen belässt oder eröffnet der Gesetzgeber den beteiligten Akteuren Verhaltens- und Entscheidungsspielräume¹¹⁰. Signifikante Beispiele für Letzteres finden sich in Regelungsbereichen, in denen man die Einschaltung Privater in die Aufgabenerledigung auch ohne ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung für zulässig erachtet, in denen

¹⁰⁸ Vgl. *Bauer* (Fn. 86), S. 254 ff.

¹⁰⁹ Vgl. zu diesem Anliegen, das zwar innersystematische Entwicklungsrückstände des Verwaltungsvertragsrechts überwinden muss, sich aber nicht als konzeptioneller Umsturz, sondern als Teil eines permanenten Modernisierungsprozesses versteht, *Bauer* (Fn. 13), § 36 Rn. 8 ff., 16 ff. m.w.N.

¹¹⁰ Die tatsächlich oder vermeintlich geringe Regelungsdichte ist einer der Anlässe für die (freilich auf Bundesebene ins Stocken geratenen) Bemühungen um eine Intensivierung der rechtlichen Rahmenbedingungen.

sich der Gesetzgeber auf den Hinweis beschränkt, dass sich die Verwaltung „zur Erfüllung ihrer Pflichten Dritter bedienen“ kann¹¹¹ oder sonst beträchtlichen Raum für die Aufgabenübertragung an Private erschließt. Dazu gehören wichtige Bereiche der Versorgungs- und Entsorgungswirtschaft wie die Abwasserbeseitigung. Dort können durch Public Private Partnerships nicht weniger als Planung, Sanierung, Ausbau, Ausrüstung, Finanzierung und der jahrzehntelange Betrieb der Abwasserentsorgungsanlage auf Private verlagert werden. In der Praxis bedeutet dies nicht selten, dass die gesamte Anlage einschließlich des Kanalnetzes zusammen mit allen weiteren sächlichen und personellen Mitteln auf den Privaten „übertragen“ wird. Allerdings können sich die Kommunen durch solche Teilprivatisierungen nicht von ihrer unaufgebbaren Letztverantwortung für die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung freizeichnen. Das wirft namentlich für die Vertragsbeendigung hochkomplexe Gestaltungsprobleme auf, weil die Kommune gleichsam „von einer Minute auf die andere“ die übergangslose Entsorgungssicherheit gewährleisten und deshalb die Aufgabe wieder selbst übernehmen können muss.

Das rückt die *zweite, die vertragliche Regelungsebene* in den Vordergrund des Interesses. Mit ihr verlagert sich die verwaltungswissenschaftliche Aufmerksamkeit auf die Vertragsgestaltung, auf

¹¹¹ So die Formulierung in § 56 Satz 3 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 31. 7. 2009 (BGBl I S. 2585). Zu der auf die in dem hier interessierenden Zusammenhang gleichlautende Vorläufernorm gestützten Verwaltungspraxis siehe *Bauer* (Fn. 70), S. 561 ff., und zu Parallelentwicklungen im Segment der Wasserversorgung *Angelika Emmerich-Fritsche*, Privatisierung der Wasserversorgung in Bayern und kommunale Aufgabenverantwortung, BayVBl. 2007, S. 1 (1 ff.).

„verwaltungsvertragliche Kautelarjurisprudenz“¹¹². Bei der vermutlich größten Public Private Partnership Deutschlands, die auf dem zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem privaten Betreiberkonsortium Toll Collect geschlossenen Maut-Konzessionsvertrag beruht, umfasst das Vertragswerk nicht weniger als 17 000 Seiten¹¹³. Solche umfangreichen Regelungswerke sind darauf angelegt, das gesamte zwischen den Parteien geltende Rechtsregime vertraglich abschließend zu regeln, was allerdings bei Toll Collect bis heute anhaltende Streitigkeiten nicht verhindern konnte. Doch ist die Vertragsgestaltung auch bei weniger bekannten Öffentlich Privaten Partnerschaften ein großes Problem. So sind bei der eben erwähnten Abwasserbeseitigung in der Vertragspraxis zur Absicherung der kommunalen Erfüllungs- oder Gewährleistungsverantwortung ganz unterschiedliche Klauseln mit teils obligatorischem, teils fakultativem Inhalt denkbar. Sie ermöglichen es der Verwaltung, im Falle einer Rekommunalisierung „die Zügel in der Hand“ zu behalten. Hervorzuheben sind als Mindestinhalte der Kontrakte effektive vertragliche Rückholoptionen¹¹⁴ zur Wahrung der Handlungsfähigkeit der Verwaltung gegenüber dem Privaten Anlagenbetreiber wie etwa die Vereinbarung von Heimfallklauseln, und zwar auch (in einem untechnischen Sinn zu verstehende) „Heimfallklauseln“ hinsichtlich des Personals, der Anlagen, der sächlichen Mittel, der elektronischen Logistik usw.

Die daran ablesbaren Tendenzen machen die Vertragsgestaltung zum Dreh- und Angelpunkt geglückter Privatisierung, zu einer

112 Begriffsprägend *Walter Krebs*, Verträge und Absprachen zwischen der Verwaltung und Privaten, VVDStRL, 52 (1993), S. 248 (271).

113 Dazu *Bauer* (Fn. 13), § 36 Rn. 42 m.w.N.

114 *Bauer* (Fn. 3), S. 275 f., 278; *Voßkuhle* (Fn. 3), S. 326; *Wollenschläger* (Fn. 106), S. 143 ff.

Erfolgsbedingung für die Kooperation von öffentlicher Hand und Privaten. Das weckt Bedarf nach einer Vertragsgestaltungslehre, die sich im Verwaltungsrecht derzeit freilich nur in ersten Umrissen abzeichnet¹¹⁵. Immerhin sind dort als wichtige Bausteine des Verwaltungskooperationsrechts neben Vertragstypen auch Vertragsklauseln wie etwa die eben erwähnten „Heimfallklauseln“ identifiziert. Auf diese Vorarbeiten der Verwaltungsrechtslehre hat unlängst der Landesgesetzgeber in Schleswig-Holstein zurückgegriffen. Das schleswig-holsteinische Gesetz über die Zusammenarbeit zwischen Trägern öffentlicher Verwaltung und Privaten¹¹⁶ enthält neben anderem nämlich auch detaillierte Vorgaben für die Vertragsgestaltung. Dazu gehören insbesondere Vertragsklauseln zur Sicherung des Einflusses der öffentlichen Hand mit entsprechenden Aufsichts- bzw. Überwachungsbefugnissen sowie über Mindestinhaltsklauseln, die sich an dem Leitgedanken der dauerhaften und sozialverträglichen Qualitäts- und Leistungserbringung¹¹⁷ orientieren und überdies vorausschauend die Rechtsfolgen bei einer Beendigung der Öffentlich Privaten Partnerschaft regeln¹¹⁸.

¹¹⁵ *Bauer* (Fn. 13), § 36 Rn. 122 ff. m.w.N.

¹¹⁶ Art. 1 des Gesetzes zur Erleichterung Öffentlich Privater Partnerschaften des Landes Schleswig-Holstein vom 19. 6. 2007 (GVBl S. 328).

¹¹⁷ Vgl. *Bauer* (Fn. 3), S. 275 f.

¹¹⁸ Insbesondere §§ 7 f. des Gesetzes (Fn. 116). Über die enormen Probleme bei unzureichenden vertraglichen Regelungen der Folgen einer Vertragsbeendigung informiert am Beispiel der Rekommunalisierung der Gasversorgung und eines Gasnetzes OLG Schleswig, NVwZ-RR 2006, S. 811 ff.

VI. Zukunftstrend (Re-)Etatisierung und (Re-)Kommunalisierung?

Die zuletzt genannten Mindestinhaltsklauseln schärfen das Bewusstsein dafür, dass der Lebenszyklus jeder Public Private Partnership früher oder später endet – sei es durch Zeitablauf, sei es durch Kündigung, sei es als Folge inhaltlichen Scheiterns oder aus anderen Gründen. Zumindest potentiell sind (Re-)Etatisierungen und (Re-)Kommunalisierungen, mit denen die öffentliche Hand eine Aufgabe ganz oder teilweise wieder unter die Fittiche nimmt, daher völlig „normale“, mitunter durch faktische Entwicklungen sogar gebotene Vorgänge. Oder anders: (Re-)Etatisierung bzw. (Re-)Kommunalisierung sind notwendige *und* unverzichtbare Alternativ- und Komplementäroptionen zur (Re-)Privatisierung.

1. Fallstudien

Zur exemplarischen Verdeutlichung mag eine Fallstudie zu Potsdam¹¹⁹ dienen: Die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam ist eine Kommune, die frühzeitig den zunächst beschrittenen Pfad der Privatisierung verlassen und alsbald den gleichsam „umgekehrten“ Weg in die Rekommunalisierung eingeschlagen hat. Wie viele andere Kommunen hatte sich Potsdam in den 1990er Jahren für eine Privatisierung der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung interessiert. 1998 kam es zum Abschluss einer Public Private Partnership

¹¹⁹ Siehe dazu *Peter Paffhausen*, Gestaltung von Public Private Partnerships – Motive, Erfolgsfaktoren, Risiken für die Kommune, Rekommunalisierung, in: Bauer/Büchner/Brosius-Gersdorf (Hrsg.), Verwaltungskooperation, 2008, S. 95 (95 ff.); *David Hachfeld*, Rekommunalisierung – Lehren aus Potsdam und Grenoble, in: Candeias/Rilling/Weise (Hrsg.), Krise der Privatisierung, Rückkehr des Öffentlichen, 2009, S. 87 (87 ff.).

mit Eurawasser. Eurawasser war damals ein weltweit agierendes Tochterunternehmen der beiden Großkonzerne Thyssen Krupp und Suez. In Deutschland konzentrierte der „global player“ seine Geschäftspolitik unter anderem darauf, Mitgesellschafter an kommunalen Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsunternehmen zu werden. Die von der Landeshauptstadt Potsdam mit der Public Private Partnership verfolgten Motive waren ähnlich wie die der seinerzeit auch andernorts zu beobachtenden Privatisierungsprozesse¹²⁰: Entlastung des Haushalts, Anlockung privater Investoren, Flexibilisierung der Personalstrukturen, Erschließung privaten know hows und privater Innovationskraft, Gewährleistung sicherer Wasserver- und Abwasserentsorgung, Kostenminimierung, Verbesserung der Servicequalität usw. Grundlage der Kooperation mit Eurawasser waren „insgesamt dreizehn sehr kompliziert ineinander greifende und somit fast schon unverständliche Verträge“¹²¹. Die Kooperationsverträge sollten auch die Einflussnahme der Stadt Potsdam auf die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung absichern, so etwa durch zugunsten der Landeshauptstadt vereinbarte Kontrollrechte, Weisungsrechte, Stimmrechte und Rücktrittsrechte.

Die Public Private Partnership geriet allerdings schon bald in eine Schieflage, die bereits im Jahr 2000 zur Rekommunalisierung führte. Ein wichtiger Grund für die Beendigung der Partnerschaft war die Entwicklung der Wasserpreise. Auf der Grundlage einer kooperationsvertraglich vereinbarten Preisgleitklausel kam es nämlich zu wiederholten Gebührenerhöhungen von anfangs 6,85 DM/m³ auf 7,86 DM/m³ im Jahr 1998, von 7,86 DM/m³ auf 8,80 DM/m³ im Jahr 1999

¹²⁰ Oben II. 2.

¹²¹ *Paffhausen* (Fn. 119), S. 99.

und einer für das Jahr 2000 geplanten weiteren Erhöhung von 8,80 DM/m³ auf 10,18 DM/m³; für das Jahr 2017 war nach den von Eurawasser vorgelegten Unterlagen eine Gesamtgebühr für Trink- und Abwasser von 16,40 DM/m³ zu erwarten. Außerdem gab es politische Kontroversen wegen des Personalabbaus. Und: Trotz der vertraglich vorbehaltenen Weisungsrechte konnte Potsdam in der Praxis keinen bestimmenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben. Am Ende der gescheiterten Kooperation stand daher die Rekommunalisierung der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung unter dem Dach der im hundertprozentigen Anteilseigentum der Landeshauptstadt stehenden Stadtwerke Potsdam GmbH, die unlängst ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert hat.

2. Von der Privatisierung zu (Re-)Etatisierung und (Re-)Kommunalisierung

Die Vorgänge in Potsdam belegen eine auch andernorts zu beobachtende Unzufriedenheit mit früheren Privatisierungsmaßnahmen. So hat man in Berlin¹²² über eine Rekommunalisierung der Wasserver- und Abwasserentsorgung nachgedacht, und in Dresden wünscht sich mancher den verkauften kommunalen Wohnungsbestand¹²³ zurück. Die zunehmende Kritik beschränkt sich nicht auf diese Einzelfälle¹²⁴ und

¹²² Dazu oben bei Fn. 57 ff.

¹²³ Vgl. oben bei Fn. 54 ff.

¹²⁴ Nach den Angaben des *Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU)*, Stellungnahme vom 18. 1. 2011 zur öffentlichen Sachverständigenanhörung des Ausschusses für Wirtschaft und Technologie des Deutschen Bundestages am 24. 1. 2011 zur „Rekommunalisierung der Energienetze“, haben sich seit dem Jahr 2007 mehr als 40 Stadtwerke neu gegründet, im Internet abrufbar unter http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a09/anhoeungen/Archiv_der_Anhoerungen/6_Oeffentlich_e_Anhoerung/Stellungnahmen/17_9_379.pdf. So gründete z.B. die Stadt Hamburg im Jahr 2009 das zu 100 % städtische Unternehmen „Hamburg Energie“, das Strom

auch nicht auf die Ver- und Entsorgungswirtschaft. Sie wirft Schlaglichter auf einen ganz allgemein zu beobachtenden Trend weg von der Privatisierung und hin zu Rekommunalisierung.

Die Trendwende überrascht, weil Privatisierung lange Zeit vielen als Königsweg zur Entlastung der angespannten kommunalen Haushalte galt. Allerdings haben bei weitem nicht alle Privatisierungsmaßnahmen die mit ihnen verbundenen Hoffnungen eingelöst. Vielmehr wird immer mehr bewusst, dass die Privatwirtschaft nicht zwangsläufig besser, effizienter und kostengünstiger arbeitet als die öffentliche Hand. Allem Anschein nach erlebt in Deutschland derzeit die Kommunalwirtschaft eine Renaissance. Das Umdenken in den Rathäusern und Kreisverwaltungen hat viele Gründe.¹²⁵ Neben Misserfolgen bei der

aus erneuerbaren Energien produziert, vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Rekommunalisierung#cite_note-18. Außerdem haben sich beispielsweise acht Gemeinden des Kreises Coesfeld, die Stadtwerke Coesfeld und die Stadtwerke Münster im Jahr 2011 zu den Gemeinsamen Stadtwerke Münsterland zusammengeschlossen und die Energieversorgung übernommen; dazu *Christoph Tesche/Sven-Joachim Otto*, Kommunale Unternehmen im Spannungsfeld von Rekommunalisierung und strategischer Partnerschaft, Power-Point-Präsentation vom 29. 9. 2011, im Internet abrufbar unter <http://www.derneuekaemmerer.de/veranstaltungen/pdf/dkt2011/Kommunale-Unternehmen-im-Spannungsfeld.pdf>. Auch die Stadt Kiel beschloss im Januar 2009 wieder 100% an den im Jahr 2003 privatisierten Verkehrsbetrieben zu übernehmen. Schon im Jahr 2003 haben die Städte Bochum und Dortmund zusammen den Konzern „Gelsen Wasser“ zurück gekauft und die Wasserversorgung wieder übernommen, vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Gelsenwasser>; *Kevin P. Hoffmann*, Die Renaissance des Staats, Tagesspiegel vom 5. 5. 2009, im Internet abrufbar unter <http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/die-renaissance-des-staates/1504000.html>; *Alexander Venn*, Rekommunalisierung als Stabilisator für die Wirtschaft, City Innovations Review, Mai 2009; im Internet abrufbar unter <http://www.cireview.de/leitlinien/rekommunalisierung-als-stabilisator-fur-die-wirtschaft/>.

¹²⁵ Vgl. dazu und zum Folgenden neben den Nachweisen in Fn. 19 etwa *Jens Libbe/Stefanie Hauke*, Rekommunalisierung – neue alte Wege der öffentlichen Daseinsvorsorge, der gemeindehaushalt 2011, S. 108 (109); *Hachfeld* (Fn. 119), S. 88 ff.; *Manfred Scholle*, Der Trend zur Rekommunalisierung – Chance oder Risiko?, in: Gernert/Konegen/Meyers (Hrsg.), Festschrift für Rüdiger Robert, 2010, S. 95 (95 ff.).

Privatisierung und Fällen privatwirtschaftlicher Schlechterfüllung sind als Motive vor allem zu nennen: ein neu erwachtes Selbstbewusstsein der Kommunen, die Wiederbelebung der kommunalen Selbstverwaltungsidee, die Rückgewinnung kommunaler Steuerungsoptionen und Einflussmöglichkeiten auf die Aufgabenerledigung einschließlich der dazugehörigen Kontrolle, die Aufbrechung monopolartiger privater Leistungserbringung mit Gewinnerzielungsinteressen, die Schaffung effizienter kommunaler Firmenstrukturen mit Rückwirkungen auf die Qualität der Leistungserbringung bei gleichzeitiger Kostensenkung für die Bürger, die Erschließung von Einnahmequellen zur Querfinanzierung defizitärer Segmente kommunaler Aufgabenerfüllung und vieles andere mehr. Inzwischen gehen von derartigen Überlegungen sogar klare Impulse für die gesetzgeberische Umsteuerung in Richtung Kommunalwirtschaft aus¹²⁶.

Zusätzlichen Auftrieb erhält der Rekommunalisierungstrend durch die Vielzahl auslaufender Kooperations- und Konzessionsverträge. Viele der in den 1990er Jahren begründeten Public Private Partnerships haben nämlich Laufzeiten von 20 bis 30 Jahren und stehen deshalb aktuell oder jedenfalls in absehbarer Zeit zur Verlängerung an. Nach Informationen des Verbandes kommunaler Unternehmen laufen in den Jahren 2010 und 2011 nicht weniger als 2000 Konzessionsverträge aus¹²⁷. In all diesen Fällen stehen die Kommunen vor der Grundsatzentscheidung, ob sie die Leistungserbringung durch Dritte fortführen oder wieder in eigene Regie übernehmen wollen. Dies legt zumindest eine intensive Beschäftigung mit Rekommunalisierungsoptionen nahe.

¹²⁶ So namentlich durch die bereits bei Fn. 76 angesprochene Trendwende bei der Ausgestaltung der Subsidiaritätsklauseln.

¹²⁷ *Hans-Joachim Reck*, Pflichten der Kommunen bei auslaufenden Konzessionsverträgen in der Energieversorgung, *KommJur* 2009, S. 401 (401).

3. Rechtlicher Rahmen und Herausforderungen

Trotz der sich mit rasanter Geschwindigkeit ändernden kommunalpolitischen Stimmungslage wäre eine unreflektierte Rekommunalisierungseuphorie verfehlt. Denn politische Großformeln wie „Kommunal vor Privat“ führen bei konkreten Modernisierungsprojekten im öffentlichen Sektor ebenso wenig weiter wie ordnungspolitische Glaubensbekenntnisse etwa nach der marktradikalen Maxime „Privat vor Staat“. Geboten ist vielmehr in jedem Einzelfall eine sorgfältige Vergleichsanalyse, die den Entscheidungsträgern spezifische Kenntnisse und detaillierte Fachkompetenz abverlangt. Dazu gehören neben praktischen Erfahrungen auch rechtliche Direktiven, die verwaltungspolitische Entscheidungen erleichtern und sie zugleich in einen normativen Rahmen stellen. Mit dem Rechtsrahmen für Rekommunalisierungsprozesse ist freilich ein neues Thema für einen anderen Vortrag benannt, das an dieser Stelle nicht zu vertiefen ist.

Wenigstens ein Aspekt sei aber kurz angedeutet. Als institutionelle Alternativen zu den zahlreichen Public Private Partnership-Konstellationen steht den Kommunen für die Erledigung ihrer Aufgaben das gesamte Spektrum an Organisations- und Handlungsformen zur Verfügung¹²⁸. Dazu gehören mit facettenreichen Abstufungen neben der kommunalen Leistungserbringung in Eigenbetrieben und Eigengesellschaften auch die vielfältigen Varianten kommunaler

¹²⁸ Vgl. dazu und zum Folgenden die Überblicke bei *Bauer* (Fn. 13), § 36 Rn. 47 ff.; *Christoph Reichard*, Institutionelle Alternativen zu Public-Private-Partnerships: Kommunale Eigenleistung, Public-Public-Partnerships und Contracting-Out, in: *Bauer/Büchner/Brosius-Gersdorf* (Hrsg.), *Verwaltungskooperation*, 2008, S. 61 (61ff.).

Zusammenarbeit etwa in Arbeitsgemeinschaften, Zweckverbänden, gemeinsamen Kommunalunternehmen sowie auf der Basis von Zweckvereinbarungen und anderen Verträgen öffentlich- oder privatrechtlicher Provenienz. Für die Kommunen, die sich in einer institutional choice-Situation befinden, erweitern solche Public Public Partnerships (PuPuP) die Optionen für die Auswahl einer für die Erledigung der jeweiligen Aufgabe passgenauen Organisation. Zur Erreichung des optimalen Designs bedürfen die Öffentlich Öffentlichen Partnerschaften einer aufgaben- und situationsadäquaten vertraglichen Ausgestaltung. Damit sensibilisieren auch Public Public Partnerships für hochkarätige Gestaltungsaufgaben und bestätigen – nicht anders als Public Private Partnerships – den herausragenden Stellenwert des Verwaltungsvertrags für das weite Feld der Verwaltungskooperation.

VII. Ausblick

Zusammenfassend gingen und gehen vom Zeitalter der Privatisierung viele Modernisierungsimpulse für das Verwaltungsrecht aus. Die Innovationen betreffen zuallererst die wissenschaftliche Analyse der Privatisierungsphänomene, der Aufgabenfelder, die Privatisierungen zugänglich sind, sowie der Vor- und Nachteile von Privatisierungen, die allgemeingültige Pauschalbewertungen verbieten. Die demnach gebotenen einzelfallbezogenen Beurteilungen werden durch die Privatisierungstypologie zwar erleichtert; gleichwohl haben die typologischen Erscheinungsformen nur begrenzten Erkenntniswert, weil in der Privatisierungspraxis hybride Mischformen namentlich der Zusammenarbeit von öffentlichen und privaten Rechtsträgern dominieren. Für die sachgerechte Strukturierung wichtiger geworden ist

die Erkenntnis, dass Privatisierungsprozesse regelmäßig mehrere Entwicklungsphasen durchlaufen. Daraus ergeben sich zunächst differenzierte Ansatzpunkte für die normative Steuerung von Privatisierungsvorgängen. Vor allem aber sensibilisiert die prozedurale Konzeption für staatliche Verantwortung, die in der Phase nach der eigentlichen Privatisierung fortbestehen kann. Eingehendere Untersuchungen haben nämlich gezeigt, dass den Staat in vielen Bereichen zumindest eine Gewährleistungspflicht für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung trifft. Das gilt nicht zuletzt für die in vielen Bereichen anzutreffenden Public Private Partnership-Arenen und macht die dogmatisch-systematische Erfassung der rechtlich gestalteten Privatisierungswirklichkeit schwierig. Als übergreifender Ansatzpunkt empfiehlt sich dafür die Erarbeitung eines Verwaltungskooperationsrechts, das zu einer deutlichen Aufwertung des Verwaltungsvertrags führt und bewusst macht, dass Öffentlich Private Partnerschaften in aller Regel früher oder später enden.

Dieses Bewusstsein schärft auch die in Deutschland zunehmend spürbare politische Trendwende von der Privatisierung hin zu (Re-) Etatisierung und (Re-)Kommunalisierung. Doch bleibt das Verwaltungskooperationsrecht auch in dem neuen Trend gefordert, weil als institutionelle Alternativen zur Kooperation von öffentlicher Hand und Privaten nicht selten Varianten interkommunaler Kooperation bzw. Öffentlich Öffentlicher Partnerschaften auf vertraglicher Grundlage im Gespräch sind. So gesehen bewirkte der Umschwung hin zur (Re-) Kommunalisierung lediglich die Neubelebung einer anderen Seite des Verwaltungskooperationsrechts, nämlich der Public Public Partnerships. Dabei zeigt die gemeinsame Klammer des Verwaltungskooperationsrechts, dass eine ideologisch eingefärbte, konfrontative

Gegenüberstellung von (Re-)Privatisierung und (Re-)Kommunalisierung verfehlt wäre. In Wahrheit handelt es sich um Entwicklungsprozesse, die sich auf einer einheitlichen Skala mit vielen Trennstrichen und Verbindungslinien bewegen. Privatisierung und Kommunalisierung sind Entscheidungsoptionen, die sich wechselseitig ergänzen und beide unverzichtbar sind, wenn in der institutional choice-Situation die Auswahl der für die Aufgabenerledigung optimalen Organisations- und Handlungsform ansteht. Deshalb ist bei solchen Auswahlentscheidungen ohne ideologische Scheuklappen die gesamte Bandbreite des verfügbaren Organisations- und Handlungsarsenals in den Blick zu nehmen und nüchtern die Leistungsfähigkeit aller Optionen für den konkreten Einzelfall zu bewerten.

Bei diesem Verständnis treten Entwicklungsszenarien einer möglichen Zeitenwende von der Privatisierung hin zu Etatisierung und Kommunalisierung zurück. In den Vordergrund tritt dann nämlich ganz allgemein der Wunsch nach einem Zeitalter guten Verwaltungsrechts, das jenseits politischer Streitschriften mit polarisierender Frontstellung von „Kommunal vor Privat“ versus „Privat vor Staat“ der Verwaltung die Institute bereitstellt, derer sie für eine zeitgemäße und optimale Erfüllung öffentlicher Aufgaben bedarf.

Literaturverzeichnis

- Appel, Ivo (2008), Das Verwaltungsrecht zwischen klassischem dogmatischem Verständnis und steuerungswissenschaftlichem Anspruch, VVDStRL 67, S. 226-364.
- Bauer, Hartmut (1987), Die finanzverfassungsrechtliche Integration der neuen Länder, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts (HStR), Bd. IX, Heidelberg: C. F. Müller, § 206.
- (1995), Privatisierung von Verwaltungsaufgaben, VVDStRL 54, S. 243-286.
- (1999), Privatisierungsimpulse und Privatisierungspraxis in der Abwasserentsorgung – Eine Zwischenbilanz, VerwArch 90, S. 561-580.
- (1999), Zur notwendigen Entwicklung eines Verwaltungs-kooperationsrechts – Statement, in: Schuppert (Hrsg.), Jenseits von Privatisierung und „schlankem“ Staat, Baden-Baden: Nomos, S. 251-272.
- (2008), Verwaltungskooperation, in: Bauer/Büchner/Brosius-Gersdorf (Hrsg.), Verwaltungskooperation, Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, S. 9-32.
- (2012), Verwaltungsverträge, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. II, 2. Aufl., Tübingen: Mohr Siebeck, § 36.
- Brüning, Christoph (2009), (Re-)Kommunalisierung von Aufgaben aus privater Hand – Maßstäbe und Grenzen, VerwArch 100, S. 453-474.
- Burgi, Martin (1999), Funktionale Privatisierung und Verwaltungshilfe, Tübingen: Mohr Siebeck.
- (2001), Kommunales Privatisierungsfolgenrecht: Vergabe,

- Regulierung und Finanzierung, NVwZ, S. 601-607.
- (2006), Privatisierung, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts (HStR), Bd. IV, 3. Aufl., Tübingen: Mohr Siebeck, § 75.
- (2008), Verhandlungen des 67. Deutschen Juristentages Erfurt 2008 Bd. I: Gutachten/Teil D: Privatisierung öffentlicher Aufgaben - Gestaltungsmöglichkeiten, Grenzen, Regelungsbedarf, München: C.H. Beck.
- Butzer, Hermann (2006), Sicherstellungsaufträge, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts (HStR), Bd. IV, 3. Aufl., Tübingen: Mohr Siebeck, § 74.
- Collin, Peter (2011), Privatisierung und Etatisierung als komplementäre Gestaltungsprozesse, JZ, S. 274-282.
- Di Fabio, Udo (1997), Verwaltung und Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher Steuerung, VVDStRL 56, S. 235-282.
- Eifert, Martin (2008), Das Verwaltungsrecht zwischen klassischem dogmatischem Verständnis und steuerungswissenschaftlichem Anspruch, VVDStRL 67, S. 226-364.
- Emmerich-Fritsche, Angelika (2007), Privatisierung der Wasserversorgung in Bayern und kommunale Aufgabenverantwortung, BayVBl., S. 1-8.
- Faber, Heiko (1992), Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Tübingen: Mohr Siebeck.
- Fehling, Michael/Matthias Ruffert (2010), (Hrsg.), Regulierungsrecht, Tübingen: Mohr Siebeck.
- Gallwas, Hans-Ullrich (1971), Die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben durch Private, VVDStRL 29, S. 211-236.
- Gramm, Christof (2001), Privatisierung und notwendige Staatsaufgaben,

Berlin: Duncker & Humblot.

Grande, Edgar (1993), Entlastung des Staates durch Liberalisierung und Privatisierung?, in: Voigt (Hrsg.), Abschied vom Staat – Rückkehr zum Staat?, Baden-Baden: Nomos, S. 371-392.

Hachfeld, David (2009), Rekommunalisierung – Lehren aus Potsdam und Grenoble, in: Candeias/Rilling/Weise (Hrsg.), Krise der Privatisierung, Rückkehr des Öffentlichen, Berlin: Karl Dietz Verlag, S. 87-98.

Hecker, Jan (2001), Privatisierung unternehmenstragender Anstalten des öffentlichen Rechts, VerwArch 92, S. 261-291.

Heintzen, Markus (2003), Beteiligung Privater an der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und staatliche Verantwortung, VVDStRL 62, S. 220-265.

Hengstschläger, Johannes (1995), Privatisierung von Verwaltungsaufgaben, VVDStRL 54, S. 165-203.

Hermes, Georg (1998), Staatliche Infrastrukturverantwortung, Tübingen: Mohr Siebeck.

Ipsen, Jörn (2011), Grundlagen des Verwaltungsrechts. Ein großer Bestand an Altem im vorgeblich Neuen, Die Verwaltung 44, S. 290-298.

Jaag, Tobias (1995), Privatisierung von Verwaltungsaufgaben, VVDStRL 54, S. 287-300.

Kahl, Wolfgang (2009), Über einige Pfade und Tendenzen in Verwaltungsrecht und Verwaltungswissenschaft – Ein Zwischenbericht, Die Verwaltung 42, S. 463-500.

Kämmerer, Jörn Axel (1996), Verfassungsstaat auf Diät?, JZ, S. 1042-1050.

——— (2001), Privatisierung, Tübingen: Mohr Siebeck.

Kirchhof, Gregor (2007), Rechtsfolgen der Privatisierung, AöR 132, S.

215-256.

Knauff, Matthias (2004), *Der Gewährleistungsstaat: Reform der Daseinsvorsorge*. Berlin: Duncker & Humblot.

Kofner, Stefan (2010), *Kommunale Wohnungspolitik*, WM, S. 20-24.

——— (2011), *Gagfah: Verfall eines Wohnungsunternehmens*, WuM, S. 205-207.

Kraft, Ernst Thomas (1982), *Das Verwaltungsgesellschaftsrecht*, Frankfurt am Main: P. Lang.

Krebs, Walter (1993), *Verträge und Absprachen zwischen der Verwaltung und Privaten*, VVDStRL 52, S. 248-284.

——— (1996), *Notwendigkeit und Struktur eines Verwaltungsgesellschaftsrechts*, Die Verwaltung 29, S. 309-322.

Libbe, Jens/Stefanie Hauke (2011), *Rekommunalisierung – neue alte Wege der öffentlichen Daseinsvorsorge*, Der gemeindehaushalt 5, S. 108-116.

Mann, Thomas (2002), *Die öffentlich-rechtliche Gesellschaft*, Tübingen: Mohr Siebeck.

——— (2002), *Kritik am Konzept des Verwaltungsgesellschaftsrechts*, Die Verwaltung 35, S. 463-490.

Lunau, Ralf (2006), *Dresdner Sozialcharta vertraglich gesichert*, Dresdner Blätt'l 4/2006, im Internet abrufbar unter <http://www.dresdnerblaetl.de/2006/04/0701.htm>.

Masing, Johannes (2002), *Stand und Entwicklungstendenzen eines Regulierungsverwaltungsrechts*, in: Bauer/Huber/Niewiadomski (Hrsg.), *Ius Publicum Europaeum*, Stuttgart: Richard Boorberg, S. 161-187.

——— (2006), *Post und Telekommunikation*, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), *Handbuch des Staatsrechts (HStR)*, Bd. IV, 3. Aufl., Tübingen: Mohr Siebeck, § 90.

- (2006), Soll das Recht der Regulierungsverwaltung übergreifend geregelt werden?, Gutachten D für den 66. Deutschen Juristentag, München: C.H. Beck.
- Maurer, Hartmut (2011), Allgemeines Verwaltungsrecht, 18. Aufl., München: C.H. Beck.
- Ossenbühl, Fritz (1971), Die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben durch Private, VVDStRL 29, S. 137-210.
- (1987), Eigentumsfragen, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts (HStR), Bd. IX, Heidelberg: C. F. Müller, § 212.
- Osterloh, Lerke (1995), Privatisierung von Verwaltungsaufgaben, VVDStRL 54, S. 204-242.
- Paffhausen, Peter (2008), Gestaltung von Public Private Partnerships – Motive, Erfolgsfaktoren, Risiken für die Kommune, Rekommunalisierung, in: Bauer/Büchner/Brosius-Gersdorf (Hrsg.), Verwaltungskooperation, Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, S. 95-106.
- Reck, Hans-Joachim (2009), Pflichten der Kommunen bei auslaufenden Konzessionsverträgen in der Energieversorgung, KommJur, S. 401-407.
- Reichard, Christoph (2008), Institutionelle Alternativen zu Public-Private-Partnerships: Kommunale Eigenleistung, Public-Public-Partnerships und Contracting-Out, in: Bauer/Büchner/Brosius-Gersdorf (Hrsg.), Verwaltungskooperation, Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, S. 61-72.
- Reimer, Franz (2010), Qualitätssicherung, Grundlagen eines Dienstleistungsverwaltungsrechts, Baden-Baden: Nomos.
- Remmert, Barbara (2003), Private Dienstleistungen in staatlichen Verwaltungsverfahren, Tübingen: Mohr Siebeck.
- Ritter, Ernst-Hasso (1979), Der kooperative Staat, AöR 104, S. 389-413.

- Röber, Manfred (2009), Privatisierung adé? Rekommunalisierung öffentlicher Dienstleistungen im Lichte des Public Managements, Verwaltung & Management, S. 227-240.
- Ruffert, Matthias (1999), Regulierung im System des Verwaltungsrechts, AöR 124, S. 237-281.
- Schmehl, Arndt. Teilprivatisierung der Daseinsvorsorge, Demokratieprinzip und Gewinnerzielungsmaxime – BerlVerfGH, NVwZ 2000, 794, JuS 2001, S. 233-236.
- Schmidt-Preuß, Matthias (1997). Verwaltung und Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher Steuerung, VVDStRL 56, S. 160-234.
- Schmitz, Heribert (2005), „Die Verträge sollen sicherer werden“ – Zur Novellierung der Vorschriften über den öffentlich-rechtlichen Vertrag, DVBl., S. 17-24.
- (2008), Kooperationsverträge, in: Bauer/Büchner/ Brosius-Gersdorf (Hrsg.), Verwaltungskooperation, Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, S. 51-59.
- Schoch, Friedrich (1994), Privatisierung von Verwaltungsaufgaben, DVBl., S. 962-977.
- (2008), Gewährleistungsverwaltung: Stärkung der Privatrechtsgesellschaft?, NVwZ, S. 241-246.
- (2008), Rechtliche Steuerung der Privatisierung staatlicher Aufgaben, Jura, S. 672-683.
- (2009), Das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht gemäß Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG als Privatisierungsverbot?, DVBl., S. 1533-1538.
- (2010), Die Rolle der Rechtsdogmatik bei der Privatisierung staatlicher Aufgaben, in: Stürner (Hrsg.), Die Bedeutung der Rechtsdogmatik für die Rechtsentwicklung, Tübingen: Mohr

Siebeck, S. 91-112.

Scholle, Manfred (2010), Der Trend zur Rekommunalisierung – Chance oder Risiko?, in: Gernert/Konegen/Meyers (Hrsg.), Festschrift für Rüdiger Robert, Mündter et al.: Waxmann, S. 95-108.

Schröder, Rainer (2007), Verwaltungsrechtsdogmatik im Wandel, Tübingen: Mohr Siebeck.

Schulze-Fielitz, Helmuth (2006), Grundmodi der Aufgabenwahrnehmung, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. I, München: C.H. Beck, § 12.

Schuppert, Gunnar Folke (1993), Verwaltungsrechtswissenschaft als Steuerungswissenschaft, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Schuppert (Hrsg.), Reform des Allgemeinen Verwaltungsrechts: Grundfragen, Baden-Baden: Nomos, S. 65-114.

——— (1998), Jenseits von Privatisierung und „schlankem“ Staat: Vorüberlegungen zu einem Konzept von Staatsentlastung durch Verantwortungsteilung, in: Gusy (Hrsg.), Privatisierung von Staatsaufgaben: Kriterien – Grenzen – Folgen, Baden-Baden: Nomos, S. 72-115.

——— (2000), Verwaltungswissenschaft, Baden-Baden: Nomos.

Stamm, Sina (2010), Eisenbahnverfassung und Bahnprivatisierung, Berlin: Duncker & Humblot.

Starck, Christian (2010), Neue Verwaltungsrechtswissenschaft?, JZ, S. 1170-1174.

Stober, Rolf (2008), Privatisierung öffentlicher Aufgaben, NJW, S. 2301-2308.

Tettinger, Peter J. (1996), Die rechtliche Ausgestaltung von Public Private Partnership, DÖV 1996, S. 764-770.

——— (2005), Public Private Partnership, Möglichkeiten und

- Grenzen – ein Sachstandsbericht, NWVBl., S. 1-10.
- Uechtritz, Michael/Olaf Otting (2005), Das „ÖPP-Beschleunigungsgesetz“: Neuer Name, neuer Schwung für „öffentlich-private Partnerschaften“?, NVwZ, S. 1105-1111.
- Uerpmann-Wittzack, Robert (2006), Verkehr, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts (HStR), Bd. IV, 3. Aufl., Tübingen: Mohr Siebeck, § 89.
- Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) (2011), Stellungnahme vom 18. 1. 2011 zur öffentlichen Sachverständigenanhörung des Ausschusses für Wirtschaft und Technologie des Deutschen Bundestages am 24. 1. 2011 zur „Rekommunalisierung der Energienetze“, haben sich seit dem Jahr 2007 mehr als 40 Stadtwerke neu gegründet, im Internet abrufbar unter http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a09/anhoerungen/Archiv_der_Anhoerungen/6_Oeffentliche_Anhoerung/Stellungnahmen/17_9_379.pdf.
- von Danwitz, Thomas (1995), Vom Verwaltungsprivat- zum Verwaltungsgesellschaftsrecht, AöR 120, S. 595-630.
- Voßkuhle, Andreas (2001), Der „Dienstleistungsstaat“: Über Nutzen und Gefahren von Staatsbildern, Der Staat 40, S. 495-524.
- (2003), Beteiligung Privater an der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und staatliche Verantwortung, VVDStRL 62, S. 266-335.
- (2006), Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. I, München: C.H. Beck, § 1.
- Weiß, Wolfgang (2002), Privatisierung und Staatsaufgaben, Tübingen: Mohr Siebeck.
- Weyand, Rudolf (2011), Praxiskommentar Vergaberecht, 3. Aufl., München: C.H. Beck.

Wieland, Joachim/Thomas von Danwitz/Thomas de Maizière (2008),
Teil M der Verhandlungen des 67. Deutschen Juristentages in Erfurt
2008.

Wolfers, Benedikt (2000), Privatisierung unter Wahrung der öffentlich-
rechtlichen Rechtsform: Der Modellfall Berliner Wasserbetriebe,
NVwZ, S. 765-767.

Wolff, Hans J./Bachof, Otto/Stober, Rolf/Kluth, Winfried (2010),
Verwaltungsrecht II, 7. Aufl., München: C.H. Beck.

Wollenschläger, Bernward (2006), Effektive staatliche Rückholoptionen
bei gesellschaftlicher Schlechterfüllung, Baden-Baden: Nomos.